

動產所有權善意取得之經濟分析*

張永健**

摘要

動產所有權善意取得制度各國均有，但內容小同大異。從美國到歐洲到臺灣對此之經濟分析理論不少，但至今未有定論。本文從配置效率與制度費用的角度切入，提出全新之思考架構。核心論點包括：嚇阻盜賊市場與竊盜行為並非善意取得制度之關懷目標。以買受人是否支付市價作為衡量原所有人與買受人孰為較能利用資源者的重要指標，落實方式為：以買賣是否符合公開市場規則，作為是否能立刻取得所有權之分野，而未支付合理市價導致買受人被推

* 投稿日：2015年10月12日；接受刊登日：2017年6月28日。〔責任校對：張幼文〕。

本文初稿發表於2015/3/31中央研究院法律學研究所個人年度學術研討會、2015/11/28北京大學法學院舉辦之兩岸四地法律發展研討會、2015/12/1上海交通大學法學院特別講座。作者感謝本刊兩位匿名審查人、出版委員會、林子儀、詹森林、簡資修、吳宗謀、許家馨、吳全峰、張善喻、詹瑋佑、吳貴亨、張憲初、桑本謙、戴昕、薛軍、陳鑫、蕭俊、崔香梅、其木提、彭誠信等教授、黃種甲之寶貴意見；感謝陳榕、陳憶馨、曾鈺琄、李孟穎、戴旻諺、劉孟涵、李彥萱、許銘軒的研究協助。本文一年多的審查期間內，筆者受邀為中國民法物權編之立法建言。筆者運用本文提出之理論，探討中國物權法的缺失和民法典的立法方向。兩篇文章針對不同法域、不同現行法為文，相關討論的字數相差約四萬字。完整的理論架構、文獻回顧、制度細節，仍請參照本文。若欲瞭解本文理論如何也能在中國適用，參見張永健，民法典立法方法論——以《物權法》第106條、第107條動產所有權善意取得為例，財經法學，2017年第4期。本文為筆者執行科技部計畫101-2410-H-001-020-MY3「占有：比較、經濟、實證分析」之部分研究成果；感謝科技部的研究補助。

** 中央研究院法律學研究所研究員、法實證研究資料中心執行長。
kleiber@sinica.edu.tw。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/41801171.pdf>。



定為「可得而知」出賣人無權處分。原所有人防範如有重大過失，不得請求善意無重大過失之買受人回復其於非公開市場購得之物。至於買受人若有重大過失，因此無法善意取得，原所有人縱有重大過失亦得請求返還。

關鍵詞：配置效率、生產效率、制度費用、交易成本、資訊成本、盜贓物規則、公開市場規則、重大過失、徵信成本、防範成本。

目 次

壹、導論

貳、理論分析框架

一、經濟分析文獻之缺陷：忽略配置效率

二、物權法規範應該兼籌併顧配置效率與生產效率

三、原所有人或善意買受人較能利用資源？

四、靜的安全與動的安全果真彼此頤頤？

參、現行動產善意取得制度無效率

一、基於「原占有人之意思喪失占有」之區分難提升配置效率

二、基於「原占有人之意思喪失占有」之區分難降低制度費用

三、防盜不應該是善意取得制度之考量

四、善意取得制度不是為了保護占有

五、占有移轉方式本身並非重點

肆、立法論：新善意取得制度之具體設計

一、以「買受人是否支付市價」為思考出發點

二、但以公開市場標準為中心設計新善意取得制度

三、公開市場標準之進一步界定

四、公開市場標準與公開市場補償規則的選擇

五、善意重大過失之界定

伍、結論

壹、導論

善意取得制度淵遠流長。數千年前的「漢摩拉比法典」(Code of Hammurabi)已有規定¹。善意取得問題恆常涉及三方(原所有人、無權處分之出賣人、善意買受人)，較許多僅在兩造間權衡的問題，更加複雜。動產所有權善意取得，除了物權法，又涉及買賣法、侵權法、刑法，關照面向甚廣。或許因為如此，即便在大陸法系中，縱使其他物權法基本規定大同小異，各國之善意取得規定，歧異之處頗多²。本問題之複雜性，引起眾多學者發之為文³；但「最好的」善意取得制度為何，至今仍無定論。

本文以經濟效率(economic efficiency)為價值判斷標準，分析何種善意取得制度較符合經濟效率之要求⁴。本文並未考慮公平、正義、自由等其他價值⁵；因此，作為立法政策分析並不完整⁶。不

1 See Saul Levmore, *Variety and Uniformity in the Treatment of the Good-faith Purchaser*, 16 J. LEGAL STUD. 43, 49-53 (1987).

2 各國善意取得規定之比較，參見楊宏暉，動產所有權善意取得制度之比較與再檢討，臺大法學論叢，41卷4期，頁1755、1757-1789 (2012年)；鄭玉山，占有改定、指示交付與善意取得——自受讓占有外觀之省思，台灣法學雜誌，134期，頁30-36 (2009年)。中國物權法之善意取得制度之介紹，吳光明，善意取得制度之設計與省思，財產法暨經濟法，11期，頁19-23 (2007年)。

3 早期的經典文獻，參見謝在全，論動產所有權善意取得，法令月刊，39卷2期，頁12 (1988年)。其餘文獻，參見後文。

4 善意取得問題之經濟分析，在臺灣並非罕見。參見王澤鑑，民法物權，2版，頁598 (2010年) (「具有分配資訊成本之作用，使權利人與受讓人均須承擔部分監控成本與資訊成本，可以降低交易成本，促進有效率利用物的資源」)；蘇永欽，善意受讓盜贓物可否即時取得？，收於：蘇永欽編，民法物權爭議問題研究，頁321-323 (1999年)；蘇永欽，動產善意取得若干問題，法學叢刊，112期，頁52 (1983年) (以下簡稱：蘇永欽，動產善意取得) (「從社會成本的觀念來看，動產善意取得制度的合法性基本上是建立在受讓人徵信成本高於權利人的防免成本，但是極端保護善意受讓人又會增加竊盜相關成本」)；游進發，占有本權與事實推定，法學叢刊，55卷3期，頁83 (2010年) (指出公示與善意取得制度可以減少交易成本)；張永健，論動產善意取得之若干問題，台灣本土法學雜誌，27期，頁105-120 (2001年)。

5 效率，如同自由、公平、正義等，都是民法重視的價值，參見例如：王澤鑑 (註4)，頁14 (「私法上二個基本原則：自由和效率」)；林俊廷，論物之經濟效

過，以往的立法政策分析，若缺少了效率觀點，同樣也有缺陷。學者寫作時，基於學術分工，埋首於自己學派的研究方法與取徑，深入挖掘問題，往往犧牲廣度。反之，立法者應該廣泛關照所有價值，也因此必須仰賴各種學派對各問題的深入分析。

作為法經濟分析的學術論文，本文第貳部分先提出分析架構。既有的善意取得問題，甚至是物權法經濟分析文獻，無論是中文或英文，並沒有提出夠清晰、夠完整的論述架構，以致於分析常有缺漏，往往只求說明某法域現行規範有一定的經濟道理，但忽略了該規範的可能成本。本文第貳部分試圖矯正此種偏頗與缺漏，提出以「配置效率」(allocative efficiency)和「生產效率」(production efficiency)為雙核心的物權法經濟分析理論框架⁷。換言之，增加配置效率與生產效率的總和，就是物權法經濟分析追求的目標。如將之應用在善意取得問題中，究竟是原所有權人還是受讓人，更能有效運用資源？哪一造更珍視系爭動產？這是本文第貳部分所要探討的問題。國內文獻常以動的交易安全與靜的安全的權衡，說明動產善意取得之立法目的⁸，本文的經濟分析理論則挑戰此種看法。

用解釋——案例事實之類型化分析，收於：司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集編輯委員會編，物權與民事法新思維：司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集，頁463-486（2014年）。

- 6 不過，效率雖然常常被拿來與公平、正義等其他價值對舉，但在民事財產法問題中，效率觀點不當然和其他價值觀點衝突。關於法經濟學方法之批評與回應，中文文獻可參見謝哲勝、莊春發、黃健彰、邵慶平、張心悌、楊智傑，法律經濟學，頁30-36（2007年）。介紹物權法中效率與其他價值對同一問題的不同分析，see GREGORY S. ALEXANDER & EDUARDO M. PEÑALVER, AN INTRODUCTION TO PROPERTY THEORY 11-104 (2012).
- 7 此種理論框架的進一步說明，請參見本文第貳部分第二節，以及張永健，物權法之經濟分析導論（二）——效率，月旦法學雜誌，231期，頁194-201（2014年）。
- 8 參見例如陳榮傳，民法物權實用要義，頁233（2014年）；劉宗榮，論所有權安全的保護與交易安全的保護，月旦法學雜誌，187期，頁59-69（2010年）。值得注意者，至少動的（交易）安全，即令在傳統論述下仍是不折不扣的效率論述。

若經濟分析的理論，可以直接運用法釋義學方法實現，就無須倡議修法⁹（修法成本也是生產效率的一環）。然而，本文第參部分論證，現行動產善意取得規定的構成要件，不符合經濟效率；而其所以不符合經濟效率，是因為現行法的文義不容許法官作最符合效率的解釋。因此，為追求更高程度的效率，本文第肆部分倡議應修正現行法律規定，提出全新的善意取得架構¹⁰。

本文第參部分明確批判現行法不符合效率處，包括：以「是否基於原占有人之意思而喪失占有」作為對受讓人異其保護之標準，沒有經濟理論支撐；防止盜賊不是物權法的功能；物權法應該保護之對象，是受讓人與原所有權人，而非原占有人。

本文第肆部分主張，應該以「是否在公開市場交易」作為區分是否保護受讓人的標準。此主張並非本文獨創，而是承襲王澤鑑教授40年前提出的洞見¹¹。以公開市場作為標準，最大的好處是受讓人在交易時，可以憑一般常識即可得知是否會確定受到保護，降低產權不確定性。此外，選擇在公開市場交易作為保護受讓人之標準

9 關於如何結合經濟分析與法釋義學方法，參見王鵬翔、張永健，被誤解的戀情——經濟分析與法學方法，2016法律思想與社會變遷學術研討會：經濟分析與法學方法，中央研究院法律學研究所主辦（2016年11月10日）。

10 誠然，善意取得規定在2009年修訂後，在實務上並無重大解釋疑義。但條文規定清楚、明確、實務可操作，不代表制度設計已經實現效率（或公平、正義）。換言之，不能由實務沒有爭議，反推現行法已經是最佳法律。立法者（以及立法論研究者）所追求者是讓民法規範更公平、更正義、更自由、更有效率……法律規範清楚，容易由法院操作，只是最基本的理性要求而已。

11 參見王澤鑑，盜賊物之牙保、故買與共同侵權行為，收於：民法學說與判例研究（二），頁229-230（1979年）（「動產能否善意取得，不宜就標的物設其區別，應依交易過程之性質而定。申言之，凡由拍賣或公共市場或由商人以善意取得者，不論其為盜賊（或遺失物）與否，均能取得所有權；反之，非依上述交易過程而取得者，縱其非屬盜賊或遺失物，亦不能取得其所有權。」）。王澤鑑教授在1978年就已經簡單扼要勾勒出以公開市場，而非以盜賊遺失物，區別善意取得與否的新制度。王澤鑑教授當年的主要目標是作判決研究，對此立法政策問題，只有寥寥數筆帶過。本文則以長篇論述證明王澤鑑教授的40年前的倡議符合經濟效率。

(而不是反其道而行)，是因為如此規定將會鼓勵有權處分物儘量到公開市場販售。而無權處分者，無論是販售盜贓物或非盜贓物，通常會傾向偷偷摸摸地在非公開市場交易。本文提出的新善意取得制度，會使得同樣外觀的物品，在公開市場的成交價高，非公開市場的成交價低。此種「分離均衡」(separate equilibrium)將使無權處分人的利潤降低，從而減少無權處分的誘因。為使民法中的規則能儘量促進配置效率，本文也提倡將未支付市價之受讓人推定為「善意但可得而知」(即現行法條所稱之重大過失)；並將未善加防範無權處分之原所有人認定為重大過失，並在受讓人支付市價、但在非公開市場購買系爭物時，例外剝奪原所有人的返還請求權。最後，本文第肆部分主張，在系爭物為替代物且對原所有人有特殊意義時，例外允許原所有人支付受讓人購買時所支付之金額，以取回系爭物。

本文以經濟分析理論建構動產善意取得法制，抽象理論部分放諸四海皆準，具體制度設計亦求能扣合臺灣的制度背景條件。為達到後者，並聚焦於真正典型的實務問題，本文梳理七年的法院判決¹²。傳統的判決評釋論文，關注法官的法律論理，褒善貶惡。本文第肆部分建構本土法制細節時，也同樣挑出值得討論的判決法律論理。

不過，梳理判決在本文更重要之目的是歸納事實態樣。善意取得之標的可以是所有權、質權或動產抵押權；善意取得的原因事實可以是買賣、互易、贈與……等等；無權處分之產生可能導因於偷

12 本文在法源法律網以關鍵字「民法第801條+民法第八零一條+民法第八百零一條+民法第八〇一條+民法第948條+民法第九四八條+民法第九百四十八條+民法第949條+民法第九四九條+民法第九百四十九條+民法第950條+民法第九五零條+民法第九百五十條+民法第951條+民法第九五一條+民法第九百五十一條」，搜尋2006年1月1日至2012年12月31日間，各級法院之民事判決，包括簡易與小額案件。共搜得270筆搜尋結果中，扣除爭點與善意取得無關之大量判決後，餘下2筆最高法院判決、20筆高等法院判決、32筆地方法院判決。

雞摸狗，也可能是所託非人；系爭動產可能是可登記的車輛，也可能是不可登記的其他動產，可能是高單價、獨一無二的世界名畫或珠寶，也可能是毫不起眼的瓦斯鋼瓶和砂石。制度設計是為了儘量完善解決大多數的典型問題，並在碰到非典型問題時，交由法官以帝王條款個案解決。因此，本文以判決中顯示的常見事實態樣¹³——無權處分人出賣動產所有權造成的善意取得¹⁴——為準，設計能解決典型問題的善意取得制度。

簡言之，本文提倡的動產所有權善意取得制度規定的法律結構，以民法第118條無權處分效力未定作為原則，善意取得規定為例外。符合善意取得構成要件者，買受人取得所有權；不符合構成要件，則處分效力未定——此時，只要原所有人無意追認此買賣，則自然可以使處分確定無效，並請求返還所有物。換言之，不採民法第949條一定年限內得請求回復之設計。最核心的構成要件是，受讓人在「公開市場」「善意不得而知」地以「市價」購買系爭物——如此就會確定取得所有權。此種設計的優點是，受讓人在購買系爭物「當時」，就可以判斷其是否能適用善意取得規定，從而降低其徵信成本。本文認為，此種制度下的資源配置，才可能符合經濟效率。

以上設計乃針對買賣而來的無權處分。最高法院86年度台上字第121號民事判決，說明民法第801條與第948條之受讓，「舉凡有交

¹³ 有進入法院的善意取得糾紛，不會是相關紛爭母體的代表性樣本。See, e.g., George L. Priest & Benjamin Klein, *The Selection of Disputes for Litigation*, 13 J. LEGAL STUD. 1 (1984); Yoon-Ho Alex Lee & Daniel Klerman, *The Priest-Klein Hypotheses: Proofs and Generality*, 48 INT'L REV. L. & ECON. 59 (2016); Theodore Eisenberg, *Testing the Selection Effect: A New Theoretical Framework with Empirical Tests*, 19 J. LEGAL STUD. 337, 339 (1990). 然而，沒有任何其他管道可以知道母體的糾紛類型，本文只能退而求其次，以訴訟案件的事實態樣，逼近母體的事實態樣。

¹⁴ 如表1所示，本文蒐集到之判決超過九成是關於動產所有權善意取得問題。而本文閱讀七年間各級法院善意取得判決，原因行為清一色是買賣。

易行為存在，不問其為買賣、互易、贈與、出資、特定物之遺贈、因清償而為給付或其他以物權之移轉或設定為目的之法律行為，均無不可」。然而，若將本文之理論架構，套用到其他原因行為，會得出與此判決不同之結論。蓋諸如贈與、遺贈、清償而移轉所有權之情形，幾乎不會發生在公開交易場所；贈與或遺贈更沒有支付合理市價。因此，受讓人無法即時取得。當然，現行法解釋論下，難以得出此種結論。這再一次說明，為何本文認為：如要使善意取得法制符合經濟效率，必須修正現行規定。

以下各章節開展本文論點。

表1 善意取得之權利客體，2006–2012年各級法院
民事判決

善意取得之權利客體	地方法院	高等法院	總計
所有權	32	16	48
質權	0	3	3
留置權	0	0	0
動產抵押權	0	1	1
總計	32	20	52

資料來源：本文製表。

貳、理論分析框架

本部分開展動產善意取得的經濟分析理論框架。第一節回顧英文的重要文獻，指出文獻均忽略了配置效率之考量，只考慮生產效率。第二節論述物權法之經濟分析應該追求配置效率與生產效率的共同極大。第三節隨即開展了文獻所缺乏的配置效率分析，提出關鍵問題：原所有人和善意買受人，誰較能利用系爭資源？第四節回應了中文文獻中常見的理論論據「善意取得乃在平衡動的安全與靜

的安全」，並主張動的安全更為重要。

一、經濟分析文獻之缺陷：忽略配置效率

本文既以經濟效率作為立法論的價值標準，在進入本文分析前，有必要先回顧幾篇主要的動產善意取得之經濟分析文獻；其他相關文獻，則在論文相關處引用。經濟分析雖然大興於美國，但早已不是一時一地之現象。不少經濟分析文獻以美國（普通）法作為分析對象，但這不表示只有美國法可以被經濟方法分析；更不表示所有採用經濟分析的論者，都企圖引入美國法。本文所探討者為臺灣民法動產善意取得制度之立法論，並無意移植美國法；本文倡議之制度也與美國法制不同。以下回顧之文獻，作者有美國人、德國人、以色列人，分析的法律有美國統一商法典、德國民法、甚至蒐羅數十國法律規範分析者。就立法論的分析路徑而言，比較法的規定都只是啟發、參考，要能從預設價值一以貫之推論出制度設計細節，才是當行本色。

2011年底，兩位美國知名的契約法經濟分析學者Alan Schwartz & Robert Scott發表一篇以比較法¹⁵與法經濟學分析善意取得之鴻文（但未論及臺灣）¹⁶，並提出前人所未見之替代制度。Schwartz & Scott從私法的基本出發點*nemo dat rule*開始談起。依照*nemo dat rule*，「自己所無之權利，不能讓與他人」（you cannot give what you don't have.）¹⁷；我國民法第118條即採此原則。但各國往往都有例外規定，也就是一般善意取得制度¹⁸。而一般善意取得制度之例

¹⁵ 歐洲各國善意取得制度之比較研究，see Arthur F. Salomons, *Good Faith Acquisition of Movables*, in *TOWARDS A EUROPEAN CIVIL CODE* 1065, 1066-74 (Arthur S. Hartkamp et al. eds., 4th ed. 2011).

¹⁶ See Alan Schwartz & Robert E. Scott, *Rethinking the Laws of Good Faith Purchase*, 111 COLUM. L. REV. 1332 (2011). 但Schwartz & Scott對其他國家民法之理解不盡正確，例如其對中國物權法之規定，就幾乎全盤誤解。

¹⁷ 參見王澤鑑（註4），頁597-598。

¹⁸ 例如：中國物權法第106條、德國民法第932條、法國民法第2276條、荷蘭民法

外，Schwartz & Scott稱之為「盜賊物規則」¹⁹（原所有人在一定時間內²⁰可請求買受人返還盜賊物）；論其實際，又回到*nemo dat rule*²¹。Schwartz & Scott認為「盜賊物規則」之下，原所有人與買受人都付出過低防範成本，但原所有人付出之搜尋失物成本則為最適²²。

「盜賊物規則」之變體則為「盜賊物補償規則」，即原所有人必須支付償金方可取回失物²³。Schwartz & Scott認為此規則造成買受人付出更低之防範成本，且原所有人付出之搜尋失物成本也低於最適²⁴。

各國善意取得法制中還有三種「盜賊物規則」之例外規定，Schwartz & Scott認為這三種例外在事前與事後都比「盜賊物規則」無效率²⁵。第一種是「公開市場規則」（*market overt rule*），即在公開市場銷售或被拍賣或公家機關變賣之贓物，善意買受人仍取得所有權²⁶。「公開市場規則」還有一個變體：「公開市場補償規則」，亦即在公開市場銷售或被拍賣或公家機關變賣之贓物，原所有人必須補償善意買受人後方能取回所有權²⁷。

第3編第86條、日本民法第192條、臺灣民法第948條。

19 See Schwartz & Scott, *supra* note 16, at 1334. 法國民法第2276條、荷蘭民法第3編第86條、臺灣民法第949條、日本第193條，即採取「盜賊物規則」。中國物權法因為當初打算以其他法律處理盜賊物，在物權法中刻意不加以規範。參見崔建遠，物權：規範與學說——以中國物權法的解釋論為中心（上冊），頁232（2011年）。

20 德國民法第935條則沒有特別對盜賊物返還請求權設定短期時效。

21 英國之普通法沒有發展出*nemo dat rule*之例外，但英國有以特別法制訂例外。See Salomons, *supra* note 15, at 1068-70.

22 See Schwartz & Scott, *supra* note 16, at 1349-50.

23 Schwartz & Scott舉瑞士民法第934條之規定為例。See *id.* at 1382. 然而，瑞士民法採用的是後述之「公開市場規則」。

24 See *id.* at 1371-72.

25 See *id.* at 1351-52.

26 See *id.* at 1334. 德國民法第935條、荷蘭民法第3編第86條即為適例。

27 法國第2277條、日本第194條、臺灣民法第950條、瑞士民法第641條即為適

另外兩種例外規定則是「可撤銷買賣規則」(voidable title rule)及「委託規則」(entrustment rule)。前者例如原所有人因受詐欺而移轉所有權給出賣人，而出賣人再移轉給善意第三人，此時第三人受到保護²⁸。後者例如原所有人將物委由販售同類物之商人保管，若商人在一般交易情境下出賣給善意第三人，此時第三人亦受到保護²⁹。兩者均規定於美國統一商法典中。有趣的是，這兩種所謂「盜贓物規則」之例外，其實就是大陸法系國家認為之一般善意取得規定。美國法律認為*nemo dat rule*與「盜贓物規則」是原則，善意取得是例外；大陸法認為一般善意取得是原則³⁰，「盜贓物規則」是例外，在比較法上確實饒富興味。

Schwartz & Scott進一步主張，傳統以物權觀點設計之善意取得制度，原所有人的防範成本與搜尋成本，以及買受人之徵信成本，不總是最適，故並無效率，故應改用侵權行為法之觀點設計一套新的善意取得制度。簡言之，若原所有人對系爭物被無權處分並無過失，則有權向善意買受人要求返還；若原所有人有過失，買受人無過失，則前者不得要求後者返還；若兩造皆有過失，則原所有人仍可要求買受人返還³¹。換言之，若原所有人無過失，永遠可以取回系爭物，無論買受人是否有過失³²。

本文對Schwartz & Scott之論述有幾點反思與挑戰：首先，Schwartz & Scott³³與其他既有文獻，似乎都隱然假設只有贓物買受

例。中國物權法第107條則對「遺失物」之無權處分採取「公開市場補償規則」。另據學者研究指出，這是從中世紀即發展出之規則。See Salomons, *supra* note 15, at 1071.

28 See Schwartz & Scott, *supra* note 16, at 1335.

29 See *id.* at 1335-36.

30 當然，若納入臺灣民法第118條無權處分效力未定之規定，效力未定可以看成原則，善意取得當成例外。

31 See Schwartz & Scott, *supra* note 16, at 1366.

32 See *id.* at 1353-57, 1366.

33 See *id.* at 1357.

人需要支付調查成本，且只有贓物之銷售價格會受到善意取得制度之影響。然而，無論是贓物或非贓物之買受人，都很難判斷所購之物是否為贓物³⁴。舉例而言，吾人走進電信行搶購iPhone 7s，要如何得知包裝盒內的智慧型手機，是店家合法進貨、侵占來、偷來、撿來？在特定情境中（如於有人在暗巷中鬼鬼崇崇兜售iPhone 7s），或許買受人會增添幾分疑心，但仍然無法精確判斷系爭物是侵占而來或偷搶而來。是故，若無一般善意取得規定及「公開市場補償規則」，則全體買受人對「幾乎所有」交易標的物都必需支付徵信成本；在無法徵信時，買受人之願付價格（willingness to pay）也都會下降，以反應購得無權處分物之風險。

而Schwartz & Scott改以侵權行為之經濟模型來思考善意取得問題，頗富新意，但本文並沒有被說服。最主要的原因是Schwartz & Scott並沒有明確地討論其經濟分析之「目標」為何。從其細部模型來看，Schwartz & Scott應該是希望原所有人能付出最適之搜尋成本與防範成本，而買受人能付出最適之徵信成本。這種思維模式本來也就是侵權行為式的，不是物權式的。Schwartz & Scott以侵權行為式之分析架構套用到物權之問題，再指責物權的思考方式不可行，多少有點打擊稻草人之謬誤。再者，如果沒有把配置效率正確地當作物權法經濟分析的目標，所謂的「最適」成本的判斷，也不會準確。

許多過去之法經濟學文獻，也都將重點放在防範成本與徵信成本（但似乎沒有文獻探討搜尋成本）。這些文獻因為也沒有考慮配置效率，所以其最適成本就直接等同於最少成本。例如：德國學者Schäfer & Ott就比較盜贓物與非盜贓物兩種情境中之防範成本與徵信成本高低，來判定德國法之規定是否具有效率³⁵。Schäfer & Ott

34 參見張永健（註4），頁115-116。

35 Schäfer & Ott的切入方式，是在侵權法常見的「最低成本防免者」（least costs

認為，一般而言原所有人之防範成本比善意取得人之徵信成本低，所以善意取得人應受保護；但在盜賊物之情境，善意取得人比原所有人能用更低之成本確認所有權歸屬，所以原所有人應受到保護。簡言之，德國法有效率³⁶。其他文獻則挑戰此種見解，有主張究竟是原所有人之防範成本還是善意取得人之徵信成本低，難以一概而論³⁷；有主張雖然在非盜賊物之情境，原所有人之防範成本低於買受人之徵信成本，但在盜賊物之情境，難以一概而論³⁸。但這些文獻都是在比較防範成本與徵信成本兩者之高低³⁹，而不是如 Schwartz & Scott將實際防範成本與最適之防範成本相比，並將實際徵信成本與最適徵信成本相比。

但以上關於防範成本、徵信成本的討論，是手段，但都忽略了物權法經濟分析的其中一個核心價值「配置效率」（詳後）。最明確探討善意取得經濟分析「目標」者是以色列學者Barak Medina，他認為目標是「極大化產權的期望價值」（maximize the expected value of the ownership right），而此價值是原所有人之保留價格與買受人

avoider) 的分析。關於最低成本防免者，參見王澤鑑（註4），頁603。對最低成本防免者視角切入善意取得問題之批評，see Barak Medina, *Augmenting the Value of Ownership by Protecting It Only Partially: The "Market-Overt" Rule Revisited*, 19 J.L. ECON. & ORG. 343, 346-49 (2003); Arthur F. Salomons, *On the Economics of Good Faith Acquisition Protection in the DCFR*, in THE POLITICS OF THE DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE 199, 214 (Alessandro Somma ed., 2009).

³⁶ 德國法善意取得規定之經濟分析，see HANS-BERND SCHÄFER & CLAUS OTT, THE ECONOMIC ANALYSIS OF CIVIL LAW 418-21 (2004).

³⁷ See ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, LAW & ECONOMICS 153 (6th ed. 2012) (但有簡短探討西班牙民法之特殊善意取得制度，認為或許是有效率之作法); Levmore, *supra* note 1, at 49. 此外，從文化差異觀點探討各國善意取得規定為何不同，see Giuseppe Dari-Mattiacci & Carmine Guerriero, *Law and Culture: A Theory of Comparative Variation in Bona Fide Purchase Rules*, 35 OXFORD J. LEGAL STUD. 543 (2015).

³⁸ See Salomons, *supra* note 15, at 1081 (引用許多文獻)。

³⁹ 也有不是比較兩者高低，而是在賽局理論模型下，考慮這兩種成本的高低，而得出善意取得制度較無善意取得之制度無效率之結論。See Caspar Rose, *The Transfer of Property Rights by Theft: An Economic Analysis*, 30 EUR. J.L. & ECON. 247 (2010).

願付價格之函數⁴⁰。此外，Medina指出，若贓物尋回率低到可以忽略不計，則買受人之願付價格不會受到很大影響，買受人也沒有誘因支出徵信成本——甚至，由事前觀點作經濟分析變得沒有意義，而應重視事後的分配問題⁴¹。不過，若不採取任何善意取得制度，則買受人之願付價格仍會受影響，從而降低所有權之「變現價值 (liquidation value)」，進一步妨礙有效率之交易⁴²。但若制度從沒有善意取得規定，轉變為採納公開市場規則，原所有人之保留價格會降低⁴³。然而，Medina沒有說明，為何善意取得經濟分析之目標，是極大化原所有人之保留價格與買受人願付價格之函數。此函數中原所有人與買受人之權重如何分配，並不清楚。為何目標不是極大化配置效率（詳後）？此外，Medina沒有明確點出來，對贓物的任何例外規範，都會影響到非贓物之無權處分物與有權處分物。

既有經濟分析文獻都仍有商榷之處，以下提出新思考架構。

二、物權法規範應該兼籌併顧配置效率與生產效率

物權法之經濟分析，以極大化經濟效率 (economic efficiency) 為依歸⁴⁴。經濟效率包括「配置效率」與「生產效率」。配置效率就是將財產權分配給較能利用者⁴⁵。換言之，制度設計者要問，在

40 See Medina, *supra* note 35, at 343, 348 (更精確說，產權的期望價值 = $a \times$ 原所有人之保留價格 + $(1-a) \times$ 買受人之願付價格)。

41 See *id.* at 345.

42 See *id.* at 347.

43 See *id.* at 368.

44 知名法經濟學者 Steven Shavell 分析本問題時，採用之極大化目標為 “the expected value of property minus the costs of efforts”。See STEVEN SHAVELL, FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 39 (2004)。筆者找不到 Shavell 更精細之解說。抽象來看，Shavell 所刻畫之目標與本文設定之目標，應屬相合。

45 參見張永健，法定通行權之經濟分析，臺大法學論叢，41 卷特刊，頁 1329 (2012 年)。See Richard A. Epstein, *On the Optimal Mix of Private and Common Property*, 11 SOC. PHIL. & POL'Y 17, 31 (1994); Thomas W. Merrill, *Accession and Original Ownership*, 1 J. LEGAL ANALYSIS 459, 488 (2009)。

善意取得之情境，系爭物對原所有人或善意買受人價值孰高。若把配置效率看成是物權法欲產出之制度產品，就不容忽略生產效率。亦即，制度設計者必須謹記：配置效率之達成，也有成本考量⁴⁶。此處之成本，廣稱為「制度費用」(institutional costs)，下面包含「交易成本」(transaction costs)和「資訊成本」(information costs)兩類⁴⁷。市場交易者要徵信，以瞭解買家的財力、賣家的信譽與商品品質、系爭物是否有權利瑕疵，是資訊成本。買家擔心徵信不完美而制訂複雜的契約條款，要求賣家提供擔保或保證，是交易成本。就善意取得問題而言，兩者的區分並不特別重要，因為都是成本，而制度設計者之部分目標是極小化制度費用，不管是哪一類的制度費用。設計、探究最有效率之善意取得制度時，必須兼籌併顧配置效率與生產效率。

對物權法經濟分析而言，最能兼顧配置效率與生產效率的機制就是自願交易。此處自願交易指有權處分。自願交易不對第三人製造外部性，並確保買方一定比賣方更珍視系爭標的物。許多民法的設計，都是為了增加自願交易的數量，減少非自願交易之數量。在即時取得問題，惡意受讓人不會取得所有權，因為已經明知交易為無權處分者，應該停止交易，並尋求與有權者協商，才能確保受讓人比所有人更珍視系爭物。不許善意有重大過失之受讓人取得所有權，以及後文提倡之使有重大過失之原所有人喪失返還請求權之設計，都是希望藉由此種誘因機制，促使每個交易者付出最適的防範、徵信成本，以求杜絕無權處分，增加有權處分、自願交易。以上事前觀點之經濟分析立法論，可以再進一步衍申：事前觀點重視

46 See Lee Anne Fennell, *The Problem of Resource Access*, 126 HARV. L. REV. 1471, 1502 (2013); HAROLD DEMSETZ, *FROM ECONOMIC MAN TO ECONOMIC SYSTEM: ESSAYS ON HUMAN BEHAVIOR AND THE INSTITUTIONS OF CAPITALISM* 109-14 (2008).

47 參見張永健，物權法之經濟分析導論（一）——事前觀點與交易成本，月旦法學雜誌，230期，頁254-260（2014年）；張永健，張五常《經濟解釋》對法律經濟學方法論之啟示，交大法學，總第13期，頁27-36（2015年）。

導正外來交易者的行為。如果法律規定無法影響交易者行為，就無法增加社會福祉。而若要影響受讓人交易行為，就無法以系爭物「是否基於原所有人之意思而喪失占有」作為區別對待之標準，因為受讓人難以辨識系爭物是否、以及因何原因而無權處分，此種規則因而無法影響其行為。相反地，受讓人可以憑常識區分交易場所是否公開，因此以公開交易場所與否區辨即時取得之效力，才可能影響受讓人行為⁴⁸。

不過，善意取得問題除了考慮事前觀點，也不得不考慮事後觀點。原因是：原所有人再怎麼防範，都還是有被偷被搶被騙的可能；受讓人謹小慎微，仍然可能獲取來路不明的物品。當無權處分在兩方已盡有效率行為時仍然發生，無權處分者又逃逸無蹤，原所有人和受讓人都無可責難，卻只有一方能帶著系爭物回家，應該如何裁決？配置效率與生產效率仍然引導思考。配置效率標準問：原所有人或善意買受人誰較能利用資源？誰較珍視就傾向分配給誰。生產效率標準問：怎麼樣的制度設計可以最大程度減少社會成本。

本文以下即開展此種分析架構，探討動產善意取得現行規範的無效率處，以及倡議較有效率的新制度。

三、原所有人或善意買受人較能利用資源？

討論從配置效率的提問開始：究竟是原所有人還是善意買受人較能利用資源？善意取得問題之所以困難，正是因為本問題之答案並不明確。一般法經濟學文獻，通常假設原所有人就是最能利用資

48 事前觀點與事後觀點分析的英文文獻，see Henry E. Smith, *Law and Economics: Realism or Democracy?*, 32 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 127, 134 (2009); Richard R.W. Brooks & Warren F. Schwartz, *Legal Uncertainty, Economic Efficiency, and the Preliminary Injunction Doctrine*, 58 STAN. L. REV. 381, 392 (2005); Lucian Arye Bebchuk, *Property Rights and Liability Rules: The Ex Ante View of the Cathedral*, 100 MICH. L. REV. 601, 603 (2001). 於善意取得問題的應用，乃本文見解，並將於後續章節更具體開展。

源者。若原所有人不是最能利用資源者，除非高交易成本作梗，真正之最能利用資源者，（會在無權處分發生前）透過交易由原所有人處購得⁴⁹。但此種假設，是因為物權法多數的糾紛源於無權使用或占有，無權占有者未曾透過自願交易而獲得物權，因而讓人懷疑其「願付價格」（willingness to pay）⁵⁰，低於原所有人之「願受價格」（willingness to accept）⁵¹；或說該物對無權者之價值，不如對原所有人之價值。

但在善意取得問題，法條已將可能適用善意保護之情境，設定在市場交易。如果善意買受人支付市價而取得系爭物，則系爭物對於原所有人或善意買受人而言何者價值較高，尚難分辨。但若無權處分之物賣價低於市價（盜賊物尤其有此可能），則善意取得人未向原所有人或其他賣家用市價購買，而向無權處分人用低於市價購買，則很可能系爭物對原所有人價值較高⁵²。我國民法與不少他國民法，相對於非盜賊遺失物之受讓人，對盜賊遺失物之受讓人保護較少，可從此觀點理解。

49 See Lee Anne Fennell, *Taking Eminent Domain Apart*, 2004 MICH. ST. L. REV. 957, 963 (2004); Thomas W. Merrill, *Incomplete Compensation for Takings Regulatory Expropriations in International Law*, 11 N.Y.U. ENVTL. L.J. 110, 119 (2002).

50 無論是經濟分析或非經濟分析理論，應該都會接受：在物權法問題，某物對當事人真正之價值（本文稱為經濟價值）很重要。但當事人心中真正的價值，幾乎不可能被外人探知。法經濟分析理論退而求其次的作法，是用願付價格與願受價格作為真正價值的替代（proxy）。這並非完美，但似乎沒有任何其他可行的、更佳方案。

51 例如：時效取得問題即是如此。相關經濟分析，參見張永健，歷久彌新或不合時宜？——民法不動產時效取得制度之實踐與革新，中研院法學期刊，18期，頁195-266（2016年）。

52 See Schwartz & Scott, *supra* note 16, at 1343. 換言之，原所有人之願受價格大於市價；但市價大於買受人之願付價格，後者又大於無權處分交易之售價。由此二條件可推知，原所有人之願售價格應大於買受人之願付價格。但請注意，實際售價與願付、願售價格，都是一個值，但市價比較適合用區間描述。因為制度費用為正，原所有人與買受人面對之市價區間不一定相同。因此，原所有人之願售價格也可能小於買受人之願付價格，但原所有人之願售價格大於買受人之願付價格，機率應該比較高。但當系爭物獨一無二時，此推論不一定成立。關於替代物與非替代物之考量，下文有更多說明。

要判斷究竟是原所有人還是善意買受人較能利用資源的另一個困難情境是：原所有人為受贈人，而買受人以低於市價購買。經濟學理首先會認為，原所有人雖然沒有付出市價以展現其願付價格，但「機會成本」(opportunity costs)的概念說明了：原所有人能以市價賣出，卻沒有這麼做，在沒有高交易成本時反映了其願付價格高於市價。因此，不能以買受人支付之價格高於原所有人，當然認為買受人較能利用資源。然而，若善意買受人也持有系爭物一段時間後，同樣也可以運用上述機會成本論證，推論善意買受人的真正願付價格也高於市價。因此，本文才一再強調，善意取得問題之所以困難，是因為配置效率之答案並不明確。

四、靜的安全與動的安全果真彼此頤頤？

如前所述，學說常見以民法第948條之規定，說明善意取得制度旨在保護動的安全；而民法第949條之例外規定，旨在保護靜的安全。保護對象的轉換，反映了兩種立法目的間的拉扯。本節提出不同看法。

(一) 以客觀標準保護動的交易安全

善意取得制度增加交易數目、便利交易，「保護動的交易安全」⁵³；換言之，可降低制度費用⁵⁴。然而，善意取得制度一旦有例外，有可能全面增加全體交易者（包括實際上是交易有權處分物之兩造）之制度費用⁵⁵，除非此例外標準乃客觀可辨，使交易者可以

53 參見王澤鑑（註4），頁597。

54 有經濟分析學者稱之為「規範面的寇斯定理」(normative Coase theorem)。See COOTER & ULEN, *supra* note 37, at 92.

55 但請注意，不少論者強調，即使沒有善意取得制度，無權處分之物之所有權均一直由原所有人保留，買方也不會花太多費用徵信，因為買到無權處分物之機會太低。See SHAVELL, *supra* note 44, at 54; Levmore, *supra* note 1, at 55, 61 n.62. 中文文獻，參見陳添輝，動產善意取得制度之起源及發展，法令月刊，66卷8期，頁1151（2015年）。

清楚知道即令標的物嗣後被認定為無權處分物，仍有善意受讓所有權之適用。民法第949條針對非基於己意而喪失占有之物之善意取得設下例外規定，但若絕大多數買受人都無法判斷系爭動產是有權處分之物、無權處分之非基於己意而喪失占有之物、無權處分之基於己意而喪失占有之物，則動產交易之制度費用就會高於沒有「例外無法善意取得」時的制度費用。這一點在國內、外文獻中，似乎未被強調。反觀本文提出之善意取得設計，客觀簡單清楚，可以讓符合公開市場規則之交易者，不用付出額外制度費用。簡言之，文獻往往強調善意取得制度在保護動的交易安全，而本文探討之新制度更能保護之。

（二）無須太重視保護靜的安全

善意取得學說所要保護之「靜的安全」，是指保護所有權⁵⁶——並可進一步以經濟語彙衍申為降低產權不確定性以提高所有權人投資意願⁵⁷、潛在買受人願付價格。配置效率在意資源能流轉到最能有效利用資源者，而較能有效利用資源者，之所以願意出更高價，往往是因為能夠在物上加工、投資、獲取物之相關資訊而作新型使用。在土地或專利，這樣的老物新用，特別明顯。在動產，尤其大眾消費商品，新型利用比較少見。增高投資意願在動產善意取得「靜的安全」的論述，就不那麼重要。所以，對大多數動產，配置效率的來源往往是：生產者可以用低於消費者願付價格的成本製造動產，並將該物賣給消費者，取得生產者剩餘（producer's surplus）。而降低產權不確定性，增加買方／消費者的願付價格，就能增加自願交易數量。

⁵⁶ 參見王澤鑑（註4），頁597。

⁵⁷ 在不動產，降低產權不確定性可以提高投資意願。經濟學者古慧雯的實證研究發現，在臺灣日治時期，先實施不動產登記制度之地區，農民比較有意願種植高價值但回收期長的經濟作物。See Hui-wen Koo, *Property Rights, Land Prices, and Investment: A Study of the Taiwanese Land Registration System*, 167 J. INSTITUTIONAL & THEORETICAL ECON. 515 (2011).

換言之，越保護所有權，買方／消費者願付價格越高。舉例而言，同樣一款汽車，在A代理商購買是100萬元加上所有民法預設的權利和物之瑕疵擔保責任，在B代理商購買是90萬元但只加上民事預設的物之瑕疵擔保責任（即無權處分時買方風險自付），許多消費者會願意付較高的價格向A代理商購買，因為產權的不確定較低。

善意取得制度影響了買受人的產權不確定性。在買受人考慮是否購買某物時，法律制度越保護善意買受人，產權不確定性越低，買受人越願意支付高價，自願交易數量增加，整體配置效率提升。然而，若買受人考慮到成為所有權人之後的情況，會赫然發現：法律制度在購買時越保護其善意受讓，就會在其成為所有權人而物被無權處分時，越不保護其所有權——產權不確定性因而上升。因此，把時間維度考慮進來後，善意取得制度之強弱，對每個人都是有時候有利、有時候不利。兩相抵銷後，很難推斷善意取得制度給予善意買受人較強的保護，整體而言是增加或減少產權的不確定性。換言之，系爭物之原所有人在系爭案件希望較強的所有權靜的安全保護，但在自己身為其他物之買受人時，又會偏好比較弱的所有權靜的安全保護。因此，無論善意取得制度對受讓人之保護是強是弱，整體而言降低產權不確定性的效果不明，無法藉由增加買方願付價格的方式，增加自願交易的數量。在此種意義上，從事前觀點，善意取得制度對所有權保護的強弱，無助於增加配置效率⁵⁸。

綜上所述，市場上所有交易者都受惠於能整體降低交易成本的制度，卻不一定偏好較為保護原所有人所有權的制度。善意取得文

58 但必須強調，這當然不表示配置效率在善意取得問題中不重要。前文提及，就算原所有人和善意受讓人都已經盡了最適的防範與徵信，仍可能發生無權處分。在無權處分已經發生後，從事後觀點，配置效率仍在乎是原所有人還是善意受讓人更珍視系爭物。善意取得規定的制度，一大部分在依據事後觀點的配置效率標準設計。接下來的第參部分第一節即是如此。

獻上常以保護靜的安全來與動的安全互相權衡，但本文主張：相對於保護靜的安全，應該更加重視動的安全。

另外也須指出者，靜的交易安全常被等同於保護原所有人，動的交易安全常被等同於保護善意買受人，但即令接受此種刻畫，此種論據仍無法直接推論出現行規範就是最能兼顧靜的和動的交易安全的制度——即何時應該保護原所有人、何時應該保護善意買受人，不當然應該以占有物喪失原因來區分。要提出此種善意取得的分析架構，仍須回到更清楚的經濟分析路徑。

如果再用另一種方式詮釋靜的安全和動的安全，將前者解釋為防範成本，後者解釋為徵信成本，則靜的安全應該重視。但此種解釋只顧及生產效率，卻完全忽略了配置效率，仍有不足。

參、現行動產善意取得制度無效率

本部分檢討現行動產善意取得制度最關鍵的無效率處。第一節與第二節分析指出，基於「原占有人之意思喪失占有」之區分，既無配置效率、也無生產效率。第三節質疑，為何要以物權法規範作為嚇阻盜賊物之工具。第四節則主張，現行規範權衡受讓人與「占有人」的利益，過度寬泛。占有人如果沒有所有權，相對於善意受讓人，並不值得保護。第五節則主張，曾在物權編修正過程中引起學說爭論的占有移轉方式，本身並非重點。

一、基於「原占有人之意思喪失占有」之區分難提升配置效率

民法第948條與第949條兩者之界線乃系爭物占有之喪失，是否「基於原占有人之意思」。此種區別標準並非最能達到配置效率者。

現行法之規範方式要促進配置效率，必須原所有人和買受人的「保留價格」⁵⁹ (reservation price；就是願付價格與願售價格的統稱)，符合以下關係：

- { 非基於原占有人之意思而喪失占有：原所有人 > 善意買受人 — (1)
基於原占有人之意思而喪失占有：善意買受人 > 原所有人 — (2)

若此兩不等式成立，民法第948條與第949條就是促進配置效率的法律規則。但是，這兩個不等式會成立嗎？任何動產都可能成為盜賊遺失物，為何在某物遺失或被竊時，原所有人的願售價格會高於善意買受人之願付價格；而在某物不是盜賊遺失物而被無權處分時，原所有人的願售價格會低於善意買受人之願付價格？很難想像此兩不等式會成立！

換個角度想，若隨意選定一個動產，如名牌鑽錶，若原所有人在遺失或被偷時，願售價格較高，不是因為遺失或失竊而被無權處分時，願售價格較低，則此兩不等式可能成立。但為何有人的保留價格會以此種方式波動？原所有人會一般而言珍視自己遺失之物勝過自己未遺失之物，違背了至少是筆者的直覺。

或者，善意買受人在得知系爭物為盜賊遺失物時，願付價格較低，得知系爭物並非因遺失或失竊而出賣時，願付價格較高，此兩不等式可能成立。或許有些買受人會因為得知系爭物為第三人所遺失或失竊，而非賣方擁有，因而降低了其願付價格。但若如此，買受人也可能會在得知系爭物乃由第三人拐騙而來時，降低其願付價格。無權處分人能擅自處理他人之物，總是導因於某些見不得人的壞事，為何買受人不會一律降低其願付價格，只會在系爭物非基於原占有人之意思而喪失占有時，降低其願付價格？

⁵⁹ 亦即，「經濟價值」(economic value)，或在賣方稱為「願售價格」(willingness to accept, WTA)，在買方稱「願付價格」(willingness to pay, WTP)。

總之，原占有人究竟是因為被詐、被騙、一廂情願、愛到昏頭、被搶、被盜、忘記……而使其物被他人處分，對其與善意買受人究竟誰是較能利用資源者，並沒有絕對關係（表2整理本文閱讀判決之喪失占有態樣，讀者可以自行比較，兩欄所列情形，是否必然對應到原占有人與善意買受人之相對經濟價值高低）。此兩不等式要成立，必須原所有人和善意買受人有非常特殊的效用函數（utility function），而多數人似乎並非此類人。如果沒有堅強的說理，可以論證在(1)和(2)中不等式多半會成立，則從事後觀點的配置效率標準，就無法證立民法第948條與第949條的規範模式。

表2 無權處分人如何獲得無權處分、占有之機會，
2006–2012年各級法院民事判決

無權處分人如何獲得無權處分、占有之機會	地方法院	高等法院	總計
基於自己意思占有而喪失占有			
受委託保管	0	3	3
寄賣	1	0	1
利用身為公司負責人、董事、經理人、股東之便	2	2	4
出賣配偶財產	1	0	1
使用借貸、租賃、附條件買賣	4	1	5
事後解除買賣、承攬契約	4	1	5
侵占	3	2	5
移轉標的物占有（作為向第三人之證明）	0	1	1
一物二賣	1	2	3
詐欺	0	0	0
非基於自己意思占有而喪失占有			
偷竊	14	6	20
收受贓物	1	0	1
強盜、搶奪	1	1	2
偽造文書（身分證）	0	1	1
總計	32	20	52

資料來源：本文製表。

二、基於「原占有人之意思喪失占有」之區分難降低制度費用

(一) 防範成本與徵信成本

民法第948條與第949條的規範模式是否能節省制度費用（即有助於生產效率）？本文亦持否定見解。與動產善意取得問題相關之制度費用有三種⁶⁰：原所有人的防範無權處分成本（簡稱「防範成本」）；原所有人之物被無權處分後，其搜尋失物成本（簡稱「搜尋成本」）；受讓人徵信、確定出賣人是否為有權處分之徵信成本（簡稱「徵信成本」）。若要像Schäfer & Ott單純比較原占有人之防範成本與買受人之徵信成本，以決定多保護盜賊遺失物，少保護非盜賊遺失物，下列兩項宣稱至少要有一項成立：

- 1) 原所有人防範動產遺失、失竊的成本高，而原所有人防範動產因其他原因被無權處分的成本低
 - 此處之邏輯必須是：防範盜賊遺失物、非盜賊遺失物兩種無權處分原因的成本是外生給定（exogenous and given），無法藉由原所有人改變行為、習慣而變化。若肯認原所有人防範動產遺失、失竊的成本高，則應該在盜賊遺失物善意取得時，特別保護原所有人。因為一旦加強保護原所有人，原所有人就不會付出高額之防範成本。反之，原所有人不能取回非盜賊遺失物，就會付出一定防範成本以避免其物被無權處分，但此處成本較低。若只在部分情況中保護原所有人，應該選擇在遺失、失竊物情境為之，因為如此可以降低原所有人的總防範成本。
- 2) 善意買受人辨識系爭物為盜賊遺失物的成本低，而辨識系爭物乃因其他原因被無權處分的成本高
 - 此處之邏輯必須是：買受人可以較輕易地辨識系爭物是盜

⁶⁰ See Schwartz & Scott, *supra* note 16.

賊遺失物或非盜賊遺失物，但要在系爭物為非盜賊遺失物時，不太知道如何分辨有權處分或無權處分。若只能在部分情境中保護善意買受人，應該選擇在非盜賊遺失物為標的時為之，因為如此可免除買受人作無謂的徵信、調查。

本文認為，這兩項陳述都不會成立，因為其背後的邏輯在大多數人身上都不適用。當然，這兩項陳述都是可能證偽的理論假說，但確實難以獲得精確數據檢驗之。不過，吾人仍可以嘗試進一步作理論推衍，挑戰這兩項命題。關於第一點宣稱，防範遺失、失竊之成本有人際差異，有人容易丟三落四，有人從不掉東西。顯然，防範遺失、失竊之成本每人不同、差異不小。立法者如何能認為，只要是盜賊遺失物，都是原所有人的防範成本比較高⁶¹？現行學說、實務將詐欺、侵占等行為歸為民法第948條之範疇，而強盜、搶奪等行為歸入民法第949條。這是因為原所有人防範詐欺、侵占容易，但阻止強盜、搶奪難？

再者，防範盜賊遺失物與非盜賊遺失物遭受無權處分的相對成本，可能有正相關（但似乎並沒有堅實的實證證據）——容易丟三落四的人，在生活其他層面也比較迷糊，例如比較容易識人不明，從而容易掉東西的人，也容易被詐欺、被侵占、被他人將東西為無權處分。若然，宣稱1)不成立。至於善意買受人之辨識成本，本文難以想像，盜賊遺失物會比較容易區辨為無權處分標的，道理何在。若宣稱2)也同樣不成立，則多保護盜賊遺失物之原所有人，無法找到降低防範成本與徵信成本方面的論理基礎。

（二）搜尋成本

至於搜尋成本，如果目標是降低（極小化）搜尋成本，則在多數國家採用的善意取得二分法框架（有時保護、有時不保護受讓

61 但請注意，表2顯示，遺失物善意取得之案例，應甚為罕見。

人)下,應該誘使原所有人在搜尋成本低時行動、搜尋成本高時放棄。在標的物為盜賊遺失物時,原所有人因為不知道無權處分人的身分,搜尋成本高⁶²;在標的物為「基於己意而喪失占有」時,原所有人有既存的法律關係可供使用(如委任、寄託、借貸、租賃),知道無權處分人之誰,搜尋成本低⁶³。因此,在此種思路之下,搜尋成本的論據會導出和現行法相反的結論。亦即,原所有人丟失物品時,應該放棄追索受讓人⁶⁴;但所託非人而致物品被無權處分時,應該循線查獲。請注意,本文並不主張此種相反的結論,因為此僅為考慮單一效率考量的結果,並非綜合考慮所有效率考量的結果。此處所論者僅是:無法從搜尋成本考量證立現行法的動產善意取得規定。

三、防盜不應該是善意取得制度之考量

若以「喪失占有是否基於原占有人之意思」設計善意取得制度值得商榷,為何許多國家如德國對盜賊物之失主,加強保護?從事後觀點考察,搜尋盜賊物本身,對失主來說有好處,但對社會而言只是財富重分配⁶⁵。而且,搜尋盜賊物的成本通常由警方負擔⁶⁶,失主因為成本外部化,更有誘因要(不論失物價格高低而)敦促警

62 在此,無論是失主自行搜尋,或警方代為搜尋,成本一般而言都會高於其他無權情境中的搜尋成本。

63 請注意,現行民法第948條、第949條並沒有完全對應到搜尋成本高低的區分。諸如侵占、詐欺被歸入民法第948條之範疇,但詐欺並不當然有既存法律關係可用(被金光黨騙的人,不知道騙子的真正身分),而侵占可能根本沒有既存法律關係。亦即,以搜尋成本而言,詐欺和侵占導致的無權處分,與竊盜或遺失導致的無權處分,沒有系統性差異。

64 絕大部分國家中,原所有人仍會將失竊一事報知警察單位,因為仍有在處分前尋回的機會。失竊後搜尋雖然從事後觀點只是資源重分配,無關效率,但可以事前嚇阻竊盜此種無效率的行為。

65 See Omri Ben-Shahar, *Property Rights in Stolen Goods: An Economic Analysis* 23 (working paper, 1997), https://pdfs.semanticscholar.org/735b/19c087829d01c3facf3b817c904a9637f960.pdf?_ga=2.148236530.436016872.1502019499-294750090.1502019499.

66 See *id.* at 22.

方搜尋。從事前觀點出發，若能找到失物，甚至小偷，可以產生事前防堵犯罪的社會好處⁶⁷。此外，保護盜賊物失主，可以讓買家躊躇不前，壓抑盜品市場，從而達到降低犯罪率之效果⁶⁸。

但是，上述說法雖有一定道理，仍無法回應以下質疑：第一，失主並不知道自己失竊之物是否已經被小偷脫手，得手者是否能善意取得；因此，失主仍有誘因尋找失物、小偷，並因而在事前嚇阻竊盜。即使如現行制度，盜賊物在兩年內無法善意取得，失主仍可能因為無法人贓俱獲而無法尋回失物。因此，是否讓盜賊物可以即時取得，對失主在事後找尋失物的誘因影響有限。

第二，買家無法辨識系爭物是有權處分物、一般無權處分物、還是盜賊物。若買家有躊躇之處，也是一般性對某些交易場所、交易條件躊躇，不會只針對盜賊物。因此，不讓善意買受人即時取得盜賊物，固然有可能稍微壓抑盜賊物交易市場，也會影響到正品的交易市場。

第三，若壓抑贓物交易、嚇阻犯罪這麼重要，為何詐欺所得之物要歸於民法第948條而非民法第949條⁶⁹？為何民法的（盜）贓物之認定要窄於刑法的贓物？而竊盜的刑事責任與侵權責任，應該要足以嚇阻大多數潛在的無權處分人，為何仍要調整物權法規定？額外課予出賣贓物之竊賊權利瑕疵擔保責任，嚇阻成效甚為有限。誠然，縱使物權法的主要功能不在於此，也可以在特殊情形納入此種

⁶⁷ See *id.* at 23.

⁶⁸ See *id.* at 24. 並參見楊宏暉（註2），頁1755。

⁶⁹ 參見最高法院40年度台上字第704號民事判例：「占有物非盜賊，亦非遺失物，其占有並具有民法第九百四十八條所定應受法律保護之要件者，所有人即喪失其物之回復請求權，此觀民法第九百四十九條之規定自明。至所謂盜賊，較諸一般贓物之意義為狹，係以竊盜、搶奪、或強盜等行為，奪取之物為限，不包含因侵占所得之物在內。」並參見最高法院22年度上字第330號民事判例：「民法第九百四十九條所謂盜賊，係指以竊盜、搶奪、或強盜等行為奪取之物而言，其由詐欺取得之物，不包含在內。」

考量。但此時就要問：物權法僅為整體法律秩序之一環，是否有別的法律可以擔負預防財產犯罪之作用？刑法是其一，侵權行為法是其二⁷⁰。即令認為刑事責任與侵權責任對出賣盜贓物者之嚇阻力不夠，則調整刑法與侵權法，應該比求助於物權法妥當⁷¹。調整物權法規定，使盜贓物之買受人比較不受保護，會增加盜贓物的故意出賣者之交易成本，確實有助於嚇阻。但此種規則同時也增加了所有其他交易者的交易成本。反之，使刑法和侵權行為法更能落實嚇阻作用，是發揮本有功能，無流弊。

如果是針對贓物買賣的需求面，則故買贓物者已經有刑事責任，因重大過失而買得贓物者，也無法適用善意取得保護。換言之，民法第949條（相對於第948條）選擇不保護的善意受讓人，是無過失或有輕過失的善意買受人。以犧牲此種善意買受人之利益，作為降低財產犯罪率的籌碼，是否允當？更重要的是，這種籌碼有用嗎？善意買受人在多數情形不可能分辨盜贓遺失物與非盜贓遺失物，也就難以在不同情境中調整自己的徵信行為。最終，只有某些不幸買到盜贓遺失物的買受人，必須乖乖交出系爭物。這只是事後的所得重分配，沒有降低財產犯罪率之效果。

本文主張，嚇阻盜贓物不是物權法的功能，不表示嚇阻無權處分不重要。較精確的說法是，對物權法而言，無權處分越少越好，有權處分越多越好（自願交易能提升配置效率）。本文所反對的說法是，在無權處分當中認為盜贓物的無權處分比非盜贓物的無權處分更值得被嚇阻。從整個法律體系之目的而言，盜贓物固然可以被認為有較高的嚇阻必要（連這一點都可以進一步深究），但此為侵

70 參見王澤鑑，侵權行為法，頁10（2009年）（論述侵權法的預防功能）。

71 或許有論者認為，刑法、民法等法律應該價值一致。但如何叫不一致，還需要細細論證。例如：侵占他人之物，並出賣善意第三人，在刑法上是犯罪，但在民法第948條之下，仍無礙於罪犯可以讓善意第三人取得所有權。如果這樣的處理並非價值不一致，為何搶奪、強盜之贓物非要讓原所有人能有機會取回，才叫價值一致？

權法和刑法之功能。物權法制度的設計則應該追求減少無權處分的數量，無論系爭物是否為盜贓物。

第四，如果警政署的統計數字可信、精準、一致，從2002年到2014年，全台的竊盜發生數，從340,536件逐年降低到75,771件⁷²。若各竊盜案件平均的失竊物品數目相去不遠，則會落入民法第949條的無權處分物，已經顯著減少。當竊盜率變得很低，以法律誘使買受人付出徵信成本，確認買賣標的物是否為贓物，越形浪費。當然，若市場上一般的交易者也知道竊盜率已經很低，買到民法第949條規範之物的機率很低，也可能決定完全不管標的物是否為盜贓物⁷³。這雖然使得民法第949條不會全面大幅增加全體交易者之制度費用，但民法第948條與民法第949條無效果的誘因設計，錯失以善意取得制度誘使交易者付出適當徵信成本之機會。

另外，警政署數據也顯示，2014年竊盜案件之破獲率已達78.1%，而且是由2002年52.6%破獲率逐年遞增⁷⁴！破獲率應該指的是找到（願意承認自己是）小偷，而不是找回失物。倘若找回失物率也夠高⁷⁵，則表示贓物還沒有被無權處分，或尚未被第三人善意受讓，則問題可以在原所有人、竊賊、故買贓物者間解決。進一步分析，仍待日後取得更多精確犯罪數據後，方能為之。

綜上所述，從經濟分析觀點，防範竊盜並非善意取得制度設計時應考量之因素。需再強調者，本文並不認為經濟效率是民法規範解釋的唯一價值，法經濟分析也不是唯一合理的方法——這僅是筆

72 參見內政部警政署全球資訊網，<http://www.npa.gov.tw/NPAGip/wSite/lp?ctNode=12593&CtUnit=2374&BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：2015年3月10日）。

73 如果竊盜率很高，但尋回失竊物之機率很低，善意取得之制度選擇，仍不會影響買家之行為。See Salomons, *supra* note 15, at 1079.

74 參見內政部警政署全球資訊網，<http://www.npa.gov.tw/NPAGip/wSite/lp?ctNode=12593&CtUnit=2374&BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：2015年3月10日）。

75 請注意，不少文獻是假設多數失竊物無法被尋回，從而影響後續推論。See, e.g., Salomons, *supra* note 35, at 209-10.

者所屬學派之方法與立場。本文之結論僅是：從經濟分析觀點，用物權法規定處理竊盜問題，並非最佳手段。不過，由其他價值出發所作之規範論據，似仍應將其所代表之價值，與經濟效率兩相權衡，而非置經濟效率於不顧。再者，即令認為有其他價值得以支持在盜賊物情境要多保護原所有人、少保護善意受讓人，似乎也應對此種價值（例如：憲法保障財產權或所有權）如何得出善意取得制度中的具體結論，多加闡釋。

四、善意取得制度不是為了保護占有

善意取得制度是為了保護所有權人，而非占有人，本文如是主張。與動產善意取得相關之條文，民法第801條雖規定於「動產所有權」乙節，且明確規定「受讓人仍取得其所有權」，但仍將部分構成要件委諸占有章的5個條文規範。民法第948條作為基礎規定，為了兼納對善意取得質權之規定（民法第886條參照），其法律效果為善意受讓人之「占有仍受法律之保護」。但是，如果沒有這一句「其占有仍受法律之保護」，善意受讓人會有任何法律保護之缺憾？不會！因為民法第801條和第886條已經分別規定受讓人取得所有權與質權。而受讓人作為物權人，民法第767條的物上請求權毋寧更為強大⁷⁶。就算善意取得人需要占有之保護，民法其他規定中，對善意無權占有人之保護，本來就不看占有之原因，所以民法第948條宣示「其占有仍受法律之保護」，並無實益，反而讓人誤會，無權處分與善意取得的整套法理，是在保護善意受讓人之占有⁷⁷。

76 參見張永健，占有規範之法理分析，臺大法學論叢，42卷特刊，頁895-896（2013年）（發現實務上有物上請求權者，不會選擇只主張占有保護請求權）。

77 早有學者主張，善意取得規定不應該放在占有章。參見蘇永欽（註4），頁51；鄭冠宇，民法物權編修正系列研討會之三——占有的相關法律問題之探討，月旦法學雜誌，66期，頁109（2000年）。但蘇永欽教授亦曾指出，民法立法者仿造瑞士民法，在善意取得規定後，立刻規定所有人與占有人的特別債權債務關係，在使未能善意取得者仍能得到合理保護。參見蘇永欽，盜賊物善意取得，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁314（2001年）。

民法第949條規定請求權人是「原占有人」，是更不恰當的設計。有學說認為民法第949條請求權主體應包括有權占有人與善意無權占有人⁷⁸；新民法第951條之1顯示，民法第949條與第950條之請求權人可以是善意無權占有人，有力地支持本說。也有學者認為民法第949條不是保護單純占有，而是有權利基礎的占有⁷⁹。本文則進一步認為，在動產所有權善意取得問題上，應該認為民法第949條或其他類型的善意取得例外規定，目的在保護原所有人。當善意買受人已經付出市價，並有效率地徵信，何以非所有權人之原占有人，要被評價為更值得保護？在請求權人為善意無權占有人時，為何法院要在已經確認請求權人雖為善意、但實無本權時，將資源判給他？無權占有人從未在市場上以出價購買顯示該資源對其之價值；相對地，善意買受人必然出了合理價格才能論為此之善意買受人。兩相比較，善意買受人是較能利用資源者之機率較高，應該選擇保護之。至於有權占有人所受之保護，並不會因為善意受讓制度轉為只保護原所有人而受影響——有權占有人可以依民法第242條代位⁸⁰原所有人請求返還盜贓物。是故，民法第951條之1、

78 參見劉宗榮，論對盜贓遺失物善意受讓人行使回復請求權之主體及其法律效果，月旦法學雜誌，100期，頁35（2003年）。

79 參見蘇永欽，動產善意取得（註4），頁51。

80 要行使民法第242條、第243條之代位權，必須符合債務人負遲延責任等條件，學說實務上有寬嚴不同的解釋。本文贊成孫森焱大法官之見解（氏並認為通說與實務亦採此立場），在債之標的與債務人之資力無關時，不以債務人無資力為行使代位權之要件；例如「承租人得代位行使出租人之所有權，對於無權占有租賃物之第三人請求排除侵害」。參見孫森焱，民法債編總論（下冊），99年5月版，頁609-610（2010年）。類似孫森焱大法官之見解，參見邱聰智著，姚志明修訂，新訂民法債編通則（下冊），新訂2版，頁95（2014年）；林誠二，債權人行使代位權之要件與限制，月旦法學教室，60期，頁8-9（2007年）（從民法第244條增訂第3項但在第242條未作類似限制，反推代位權之行使，不以債務人限於無資力為要件）。另可參見黃茂榮，債法總論（三），3版，頁129-144（2010年）。

實務見解，參見最高法院103年度台上字第2333號民事判決、最高法院101年度台上字第1657號民事判決、最高法院89年度台上字第744號民事判決、最高法院88年度台上字第650號民事判決（「除在特定債權或其他與債務人之資力無關

第949條、第950條選擇保護無權占有人，而不保護善意買受人，不是最有效率之制度設計⁸¹。

在本文所閱讀之2006年至2011年地方法院與高等法院善意取得判決中，有些原告是物之原所有人，請求返還無權處分物；有些原告是善意（或後來被法院認定為惡意）之動產受讓人，提訴確認所有權存在。法院在權衡保護之對象，沒有任何單純占有人，都是善意受讓人或原所有人。故保護單純占有人有無實益，也可置疑。

五、占有移轉方式本身並非重點

新民法第948條第2項，參照德國民法第933條，要求占有改定之交付，必須在善意受讓人取得現實交付時，才能取得所有權。然而，若以指示交付方式移轉占有，則善意受讓人立即可以取得所有權⁸²。此種形式區分，有學者批評，動產占有之受讓，以占有改定方式為之，並不減少受讓人信賴之正當性⁸³。亦有學者批評，要求善意取得必須現實交付，只是讓受讓人先取得現實交付，再移轉占有給出賣人⁸⁴。

本文主張，誰占有、如何移轉占有「本身」，並不是善意取得問題之思考重點⁸⁵。承前，善意取得制度中拔河的两造是原所有人

之債權，不問債務人之資力如何，均得行使代位權外，如為不特定債權或金錢債權，應以債務人怠於行使其權利，致陷於無資力，始得認有保全之必要。」)、最高法院87年度台上字第458號民事判決、最高法院87年度台上字第2170號民事判決、最高法院85年度台上字第1752號民事判決。

81 對於保護無權占有之批評，參見謝在全，民法物權論（下冊），4版，頁537（2009年）；王澤鑑（註4），頁632。

82 依德國民法第934條，指示交付之情形：（1）若出賣人為物之間接占有人，讓與請求權時起善意取得；（2）若出賣人不是物之間接占有人，自直接占有時起善意取得。

83 參見陳忠五，2010年民事法發展回顧，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1719（2011年）。

84 參見楊宏暉（註2），頁1799。

85 請比較陳添輝，是否得以占有改定之方式善意取得動產所有權？，法令月刊，

和善意受讓人。在乎經濟效率的立法者或法官，想要在成本最小的條件下，將資源分配給較能利用者手中。在原所有人與善意受讓人已經善盡防範與徵信成本之前提下，以配置效率與生產效率作為決定孰勝孰負。而占有與占有移轉之方式，可以幫助判斷前述效率要素，但從經濟分析觀點，本身沒有值得善意取得制度保護之處。

詳言之，認定現實交付或簡易交付足以構成保護善意受讓人之重要條件，是因為現實交付或簡易交付時，受讓人必定曾經或長期現實占有系爭物。善意買受人若不曾有事實上管領力，不一定有檢驗、把玩系爭物之機會。買受人得以親身碰觸實物，才有切實徵信之可能——標的物上之刮痕、包裝方式、名稱縮寫、流水號碼……這類資訊都可能讓買受人心生懷疑，從而質疑出賣人之處分權源。而若標的物上沒有可疑處，買受人之善意方有所本。再者，買受人若長期有事實上管領力，可能會開始投資其上，親自動手改善，或因為取得而產生感情——心理學上稱之為「稟賦效應」(endowment effect)⁸⁶。這些會是傾向於保護受讓人之理由。

就此來看，在指示交付時，除非買受人有在第三人處查驗過標的物，並對第三人與出賣人之關係有合理認識，否則本文會傾向於將買受人之善意論為有重大過失之嫌。在極端情形，買受人只是相信（初見面的）出賣人的隻字片語，也未和當時占有系爭物的第三人有任何接觸或查證，就接受出賣人讓與之返還請求權，以代交付，則絕大多數情形下應論為有重大過失，而不受善意取得保護。

而在占有改定之情形，若買受人是融資性租賃的廠商，出賣人是工廠，標的是機器，則若買受人已經盡了業界標準作業程序會作

58卷12期，頁45（2007年）（動產善意取得制度，重在讓與人占有動產，而不是讓與人移轉占有之方式）。其他關於占有改定與善意取得之探討，參見溫豐文，占有改定與善意取得，台灣法學雜誌，99期，頁188-190（2007年）。

⁸⁶ 關於稟賦效應，see DANIEL KAHNEMAN, THINKING, FAST AND SLOW 289-99 (2011).

的合理查證，應該有論為無重大過失善意取得人之空間。「買後租回」的融資性租賃交易，買受人可能直到機器報廢都不會取得現實占有，一律無法善意取得，有失其平。而在另一類（極端）案例中，買受人所相信、所取得者只有一個間接占有人、出租人之地位，自始沒有查驗過系爭標的物，則新民法第948條第2項不允其取得所有權，也不算冤枉。

所以，就結論而言，本文贊成學者所論，無須直接在善意取得之構成要件上規範動產所有權買賣之交付方式，而留待法院在個案中在「重大過失」要件中判斷⁸⁷。

最後，值得注意者，雖然占有改定與指示交付之學術討論不少，但在實務之運用——至少在善意取得問題——則甚為罕見。如表3所示，本文閱讀之判決中，僅有一個判決涉及占有改定，沒有判決涉及指示交付。

表3 受讓占有之態樣，2006–2012年各級法院民事判決

受讓占有之態樣	地方法院	高等法院	總計
現實交付	28	15	43
簡易交付	1	0	0
占有改定	0	1	1
指示交付	0	0	0
無交付之事實	3	4	7
總計	32	20	52

資料來源：本文製表。

⁸⁷ 參見蘇永欽，動產所有權的代理取得，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁53（2001年）；謝哲勝，民法物權，4版，頁500（2012年）。See also Arthur Salomons, *The Purpose and Coherence of the Rules on Good Faith Acquisition and Acquisitive Prescription in the Draft Common Frame of Reference: A Tale of Two Gatekeepers*, 21 EUR. REV. PRIVATE L. 843, 856 (2013).

肆、立法論：新善意取得制度之具體設計

第貳部分提出理論架構，第參部分用以論證何以現行善意取得制度不符合效率。本部分將論證以公開市場規則，搭配未支付市價推定重大過失之制度，最符合經濟效率。本部分要進入比較細節的制度設計；但在進入具體問題前，有必要讓讀者有點「現實感」：動產千千萬萬種，什麼樣的動產之善意取得，會鬧上法院？價格高、有點獨特、能夠辨識的動產，可以想見會是最可能之標的。

但一位作者的想像力往往比不上大千世界。因此，本文梳理七年的善意取得判決，以瞭解善意取得問題牽涉的動產類型⁸⁸。此部分純然是判決事實的梳理，而不是判決法律見解的批判。為何要知道動產類型？因為不同動產交易隱含的資訊成本不同，連帶影響立法論的探討方向與制度設計模式。如果善意取得標的都是教科書上常出現的汽車，則立法制度設計上會走向強化汽車車牌甚至引擎的登記制度。換言之，藉由登記制度所降低的資訊成本與其公示作用，使善意受讓人絕跡。但若實務上遭遇的善意取得動產千奇百怪，多未經登記，也難以登記，此時，善意取得制度設計，就不能仰賴登記制度，而要權衡配置效率與生產效率後，在特定條件下保護其中一造。

在本文閱讀之判決中，（可以登記的）車輛⁸⁹、（教科書中出現

⁸⁸ 此外，梳理判決的另一個主要目的，是鑒往知來並以具體事例舉例。法經濟分析的理論架構，不一定為所有法律人所熟知。本文倡議的具體制度設計，若停留在抽象論述，讀者難免有不易理解之處。因此，藉由批判判決的法律論理，可以凸顯本文制度設計的獨特之處。而以法院在具體議題中認事用法舉例，有助於澄清立法論的內容。

⁸⁹ 臺灣高等法院98年度上字第88號民事判決（轎車）、臺灣高等法院96年度上易字第505號民事判決（轎車）、臺灣高等法院臺南分院95年度上易字第52號民事判決（轎車）、臺灣臺北地方法院95年度訴字第270號民事判決（轎車）、臺灣臺北地方法院96年度訴更一字第17號民事判決（轎車）、臺灣臺北地方法院96年度簡上字第111號民事判決（轎車）、臺灣臺北地方法院95年度北簡字第

的)名錶⁹⁰確實出現頻率不低,但也有難以預料的物權類型,值得逐一列出,有助於學說實務人士進一步思考善意取得問題時,作為真實之考量客體⁹¹:電纜線⁹²、砂石⁹³、木材⁹⁴、股票⁹⁵、建材或工程相關原料⁹⁶、路燈⁹⁷、瓦斯鋼瓶⁹⁸、船模及甲板⁹⁹、電子儀器設

57353號民事簡易判決(轎車)、臺灣臺北地方法院95年度北簡字第11591號民事判決(轎車)、臺灣臺北地方法院94年度訴字第1787號民事判決(轎車)、臺灣板橋地方法院96年度板簡字第10850號民事判決(廢棄轎車5部)、臺灣臺中地方法院95年度訴字第1301號民事判決(轎車)、臺灣臺中地方法院95年度訴字第1270號民事判決(自用小客貨車)、臺灣高雄地方法院99年度鳳簡字第439號民事判決(機車)、臺灣桃園地方法院95年度訴字第364號民事判決(自用小貨車)、臺灣臺中地方法院97年度沙簡字第237號民事判決(營業大貨車)。

90 臺灣高等法院101年度上易字第649號民事判決(勞力士手錶)、臺灣板橋地方法院101年度訴字第140號民事判決(勞力士手錶)(本案之上級審為前述臺灣高等法院101年度上易字第649號民事判決)。

91 善意取得制度在國際上最重要的應用是失竊藝術品(尤其是畫作)的善意取得問題。專文經濟分析, see William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economics of Legal Disputes over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles*, in *ECONOMICS OF THE ARTS: SELECTED ESSAYS* 177, 192-93 (Victor Ginsburgh & Pierre-Michel Menger eds., 1996)。失竊藝術品善意取得問題,因往往涉及不同國家法域,關於國際私法上如何選法及如何選定管轄法院之經濟分析, see Daniel Klerman, *Jurisdiction, Choice of Law and Property*, in *LAW AND ECONOMICS OF POSSESSION* 266 (Yun-chien Chang ed., 2015)。

92 臺灣高等法院98年度上易字第769號民事判決(電纜線約5,544公斤)、臺灣臺北地方法院98年度訴字第276號民事判決(廢棄電纜線)。

93 臺灣高等法院臺南分院97年度重上更(一)字第11號民事判決(合計為20,078.933立方公尺砂石)、臺灣高等法院臺南分院99年度重上更(二)字第9號民事判決(合計12,660.59立方公尺土石)、臺灣臺南地方法院94年度重訴字第56號民事判決(砂石46,588.32立方公尺)。

94 臺灣高等法院臺中分院97年度訴易字第30號民事判決(長度615公分、寬度147公分、高度87公分之紅檜)、臺灣苗栗地方法院101年度簡上字第39號民事判決(25公噸的樹齡50餘年之本土臺灣柚木)、臺灣苗栗地方法院100年度苗簡字第475號民事判決(25公噸的樹齡50餘年之本土臺灣柚木)(本案之上級審為前述臺灣苗栗地方法院101年度簡上字第39號民事判決)。

95 臺灣高等法院99年度重上字第233號民事判決(永盛公司股票280萬股;股票之讓與擔保事實發生於1998年)、臺灣高等法院臺中分院96年度重再更(一)字第1號民事判決(味全食品工業股份有限公司股票7千股、東元電機股份有限公司股票1萬股、亞洲水泥股份有限公司股票1萬股、新竹區中小企業銀行股份有限公司股票1萬9千股、南亞塑膠工業股份有限公司股票3萬3千股;股票讓與之原因事實發生於1994年)。

96 臺灣臺中地方法院100年度訴字第1619號民事判決(輕隔間骨料共計2,500公

備¹⁰⁰、工程機械¹⁰¹。

以下第一節主張，以買受人是否支付市價，最能（在資訊成本非常低時）判斷買受人之願付價格是否夠高。然而，因為資訊成本並不低，第二節主張改以公開市場規則作為即時取得與否之界定；並由現行民法第950條之定義入手，展開制度設計細節之討論。本節之理論論據，多半也可以用以解釋現行民法第950條。第三節進一步探討公開市場標準的細節設計。第四節探討使用公開市場補償標準的時機。第五節則關注（本文贊成之）新民法第948條「重大

斤）、臺灣嘉義地方法院97年度嘉簡字第5號民事判決（約16,470公斤之鋼板1批）、臺灣臺南地方法院98年度訴字第623號民事判決（308,840公斤之鋼材）、臺灣高雄地方法院98年度重訴字第346號民事判決（長16公尺、寬40公分，每片重量960公斤之鋼板樁，共600片）、臺灣高雄地方法院98年度重訴字第81號民事判決（總值9,390,000元之鋼材）、臺灣高等法院100年度重上字第443號民事判決（鋼材乙批）、臺灣高等法院高雄分院99年度重上字第24號民事判決（350×350 H型鋼、400×400 H型鋼，共值939萬元及鐵板）、臺灣高等法院高雄分院99年度重上字第24號民事判決（支扣押型鋼）。

97 最高法院99年度台上字第1012號民事判決、臺灣高等法院96年度重上更（一）字第40號民事判決（本案之上級審為前述最高法院99年度台上字第1012號民事判決）。

98 臺灣南投地方法院97年度投簡字第646號民事簡易判決。

99 臺灣高雄地方法院99年度重訴字第91號民事判決（48呎船模及甲板）。

100 臺灣臺中地方法院100年度訴字第1619號民事判決（綜合測試儀11台、電源供應器5台）。

101 最高法院99年度台上字第1147號民事判決（機械）、臺灣高等法院高雄分院98年度上易字第193號民事判決（挖土機）、臺灣高等法院高雄分院99年度上字第80號民事判決（TCM牌中古堆高機FD240T3m甲側及移芽叉1台）、臺灣高等法院高雄分院101年度再字第8號民事判決（TCM牌中古堆高機FD240T3m甲側及移芽叉1台）、臺灣高等法院97年度上字第768號民事判決（機械）（本案之上級審為前述最高法院99年度台上字第1147號民事判決）、臺灣高雄地方法院97年度訴字第1852號民事判決（挖土機及弄斗各壹台）、臺灣高雄地方法院94年度訴字第2141號（挖土機乙台）、臺灣高雄地方法院98年度訴字第111號民事判決（TCM牌中古堆高機FD240T3m甲側及移芽叉1台）（本案之上級審為前述臺灣高等法院高雄分院99年度上字第80號民事判決、臺灣高等法院高雄分院101年度再字第8號民事判決）、臺灣臺北地方法院94年度訴字第5921號民事判決（4部挖土機）、臺灣板橋地方法院98年度訴字第1762號民事判決（工程設備）、臺灣彰化地方法院99年度訴字第947號民事判決（三菱牌180型挖土機1臺）。

過失」之經濟解釋，並倡議考量原所有人之重大過失。

一、以「買受人是否支付市價」為思考出發點

本文第參部分論證，現行民法以是否出於己意喪失占有作為區辨善意受讓人是否可以立即、終局取得系爭物所有權之設計，沒有配置效率的理由。從配置效率出發，應該將系爭物分配給價值較高者。本節探討如何以新制度更準確地將系爭物分配價值較高者。

以「買受人是否支付市價」作判斷標準，較現行法為優。買價低於市價，表示買受人之願付價格可能低於市價，又因為原所有人的願受價格（或言其經濟價值）大於或等於市價¹⁰²，則讓原所有人保有所有權，較可能提升配置效率¹⁰³。買價等於市價，則難以判斷原所有人或善意買受人誰的價值高。至少，立法者知道，若以配置效率之論理為基礎，對兩種善意買受人區別保護，應以是否支付市

102 Fennell, *supra* note 49, at 963; Merrill, *supra* note 49, at 119.

103 支付價格低於市價，最極端情形就是無償取得。有學者認為，無償受讓不受善意取得保護，本文贊同。參見謝哲勝，無償受讓可否主張善意受讓，月旦法學教室，86期，頁14-15（2009年）；謝哲勝（註87），頁500-501（主張由民法第950條「……以善意『買得』者」之文義，表示受讓人乃有償取得，此呼應善意受讓應限於有償受讓之見解）。民法物權編修正時，修法委員熱烈討論此問題，並各有立場。參見法務部編，民法物權編研究修正實錄——通則、所有權、用益物權、占有及施行法（四），頁2561-2568、2600-2604（2009年）（陳忠五、謝哲勝、陳榮隆等修法委員傾向認為善意取得應限於有償，朱柏松、吳瑾瑜等修法委員傾向認為不應限於有償）。

比較困難的案件類型，是原所有人和受讓人都是受贈人，換言之兩造均未曾付出市價以取得系爭物。如果原所有人在喪失占有前，已經受贈許久，則由配置效率觀點，原所有人應該較可能是價值較高之一造，原因是：機會成本就是成本。原所有人長期持有，而未以市價讓售該物，表示其保留價格大於或等於市價。而糾紛中之受讓人通常受贈未久。此時，受讓人之保留價格是否大於、等於或小於市價，尚難以判斷；蓋交易成本為正，受讓人即令保留價格低於市價，仍須時間處理讓售事宜。但若原所有人和受讓人都是甫受贈，則配置效率觀點無用武之地。但由生產效率觀點，此時不宜為此等罕見特殊案例，添設例外規定。若能回歸本文提倡之以市價受讓之架構，法律制度比較單純而可預見。故結論是，不需要考慮原所有人是否為受贈人；只要受讓人無償受讓，就不受善意取得制度保護。

價為準，因為至少可以區隔出不值得保護之買受人。反觀現行法，民法第949條之非基於己意而喪失占有之物，轉賣時售價低於民法第948條之基於己意而喪失占有之物，雖屬可能，但差異較不顯著¹⁰⁴。準此，「支付市價」標準，比「己意喪失占有」標準，並能扣緊配置效率。

二、但以公開市場標準為中心設計新善意取得制度

「支付市價」標準，相較於「公開市場」標準¹⁰⁵，雖然在制度費用幾近零的理想世界中，更能達成配置效率；但因為現實世界中的制度費用為正、有時很高，綜合考量制度費用與配置效率後，公開市場標準比支付市價標準更符合效率。公開市場標準也是本文主張的善意取得立法論中的關鍵設計¹⁰⁶。

先敘明公開市場標準的具體內涵：善意無重大過失之買受人若符合公開市場標準，可以取得所有權。若買受人善意無重大過失，但不符合公開市場標準，買賣效力未定；有支付合理防範成本之原所有人，得向善意受讓人請求返還，無須償還支出之價金。若原所有人有重大過失，而買受人善意無重大過失，但未在公開市場購買，則原所有人例外地失去返還請求權。若買受人為惡意，則原所有人縱有重大過失仍可請求返還。換言之，在本文見解下，無權處分原則上都是效力未定，只有在買受人善意無過失且由公開市場中購買時，才能即時取得。這是簡單清楚的二分法。若立法者同意本文後述之原所有人偶爾付出過低防範成本問題，則可以如上所言，加設原所有人例外喪失返還請求權之規定，是二分法的例外。二分

104 值得一提者，魁北克民法典就不區分原所有人喪失占有之原因是否為自願。
See EIAN MACKAAY, LAW AND ECONOMICS FOR CIVIL LAW SYSTEMS 281 (2013).

105 本文第貳部分所謂之「公開市場規則」，是學者用以描述盜贓物不能即時取得之例外。本文以下所稱之「公開市場標準」，則是指以系爭物是否在公開市場或由專業商人出售而判斷是否能由受讓人確定取得所有權。

106 參見張永健（註4），頁117-120。

法與此例外的經濟論證彼此相關，但並非互為前提，所以支持其一者不當然必須支持其二。此外，為免公開市場交易價格低於市價，讓配置效率之判斷失去準頭，公開市場標準可以再加上：受讓人未支付合理價格者，推定為重大過失¹⁰⁷。

公開市場標準比支付市價標準更有效率的關鍵原因是減少買受人不必要之資訊成本與交易成本。無權處分者，無論處分標的是否為盜贓物，會儘量避免拿到非虛擬世界的公開交易場所來賣，否則可能暴露行蹤而被查獲（關於虛擬世界之論述，詳後）。而無權交易者若找上「販賣與其物同種之物之商人」（以下簡稱為「專業商人」），例如把偷來的汽車賣給二手車商，也可能因為專業商人具備判斷真假與權利歸屬的專業知識（如從車牌查所有權人與比對引擎號碼），而事跡敗露。因此，在公開交易場所中出賣之物，與專業商人所賣之物，通常都伴隨處分權。準此，只要買受人付出合理的徵信成本而成為非可得而知，一律讓買受人取得所有權，是因為公開市場中、專業商人所賣之動產，絕大多數情形本來就是有權處分；而在少數無權處分情形，選擇保護（與原所有人同樣值得保護之）買受人，讓全體付出最適徵信成本之買受人都可以無須擔心無法獲得物權，因而節省徵信成本。

相對地，在支付市價標準下，買受人整體的徵信成本較高。因為市價是區間，買受人所支付之價格是否落於法院認定之市價區間，較為不確定¹⁰⁸，此種不確定性使買受人會因為較無法確定自己是否會即時取得而多付出徵信成本（事後也會引發較多原所有人與

107 專業商人與公開交易場所中的賣家，在市場競爭下，其報價通常趨近於市價。此種趨勢，是採取公開市場標準的配置效率理由。如前所論，買受人願意支付市價，才代表其願付價格可能不低於原所有人。此處加上推定重大過失的規範，是為了確保在市場競爭失靈時，配置效率的論據仍能成立。

108 例如臺灣有蓬勃的二手單眼相機鏡頭交易市場，而全新鏡頭之市價，常常因為匯率或新品上市而波動；二手鏡頭價格又受到耗損狀況之影響；故市價為何，往往難以判斷。

善意受讓人間之訴訟)。再者，無權處分物在支付市價標準下，可由其處分者毫無懸念地標示以市價出賣，因為處分者不用擔心以市價出賣會更容易被抓包。因此，當其他條件一致，支付市價標準下被善意取得的無權處分物，佔總交易之比率較高；公開市場標準下被善意取得的無權處分物，比率較低。用賽局理論的術語，公開市場標準比較能促成「分離均衡」(separating equilibrium)，而非「混合均衡」(pooling equilibrium)¹⁰⁹。換言之，大多數無權處分物會在非公開市場販賣；有權處分者有誘因到公開市場出售。因此，公開市場上販售之物大多是有權處分物，而非公開市場上會有比率更高的無權處分物。

公開市場標準較好地達成分離均衡，對受讓人支出徵信成本以成為不得而知（即現行法所謂之無重大過失）影響至深。如本文第四部分第五節所論，依照經濟分析理論，所謂不得而知，是指受讓人已經支出最適徵信費用，仍無法得知系爭物被無權處分。而最適徵信費用的計算與系爭物被無權處分之機率關係最大。在公開市場標準創造的分離均衡下，公開販售之物是被無權處分的機率低，最適徵信費用就降低，因此所有受讓人有誘因、會實際支出的徵信費用就低。反之，在支付市價標準，最適徵信費用較高，整體實際支出的總徵信費用也較高。

公開市場標準較好地達成分離均衡，也引導受讓人的採購行為，並影響無權處分人行為。在公開市場標準下，只想購買有權處分物之理性受讓人可以推知，去公開市場或從專業商人處購買，幾乎沒有風險；不由此途，風險高而需支出的徵信費用也高。受讓人因此會偏好在符合公開市場標準處購買。相對地，在現行法下，民法第950條也給予去公開市場或從專業商人處購買者補償，但一來，此種補償不如確定讓受讓人可以即時取得；二來，若系爭物基

109 See DOUGLAS G. BAIRD ET AL., GAME THEORY AND THE LAW 83 (1998).

於己意而喪失占有時，就算不符合公開市場標準也可以即時取得，使得是否去公開市場或從專業商人處購買的風險差距、徵信費用差距，不如本文提倡之制度來得大，因此誘導受讓人至公開市場採購之效果沒有這麼強。而受讓人越少到非公開市場採買，無權處分物較「安全」的銷售管道就越窄，交易減少、獲利下降，也進一步降低了無權處分的誘因¹¹⁰。

三、公開市場標準之進一步界定

本文立法論倡議採用「公開市場標準」作為區分即時取得與否之標準。現行民法第950條採取之公開市場規則，與本文提倡之公開市場標準，都以標的物在「公開交易場所」販售，或標的物由「販賣與其物同種之物之商人」販售界定。但此二條件之精確意義為何，本文閱讀之判決幾乎沒有正面界定過。少數的例外，如：臺灣高等法院臺中分院96年度重再更（一）字第1號民事判決，及再審之臺灣高等法院臺中分院93年度金上更（二）字第2號民事判決，僅以傍論¹¹¹提及「股票交易市場」屬公開交易場所。臺灣臺北地方法院96年度簡上字第111號民事判決（系爭標的物為汽車）¹¹²，則認為「當舖業者顯非屬公共市場亦非專為販賣汽車之商人」。同見解，參見臺灣臺北地方法院95年度北簡字第57353號民事簡易判決。（在本文閱讀之判決中，公開交易場所之案件少，專業商人之案件多，參見表4。）

法院判決沒有釐清公開市場標準的範疇，學說也沒有提出以公開市場標準作為標準的完整經濟分析。本節第一小節主張公開交易場所可以由買方或賣方開設。第二、三小節探討拍賣與線上買賣是

¹¹⁰ 參見張永健（註4），頁117-118。

¹¹¹ 兩個判決最後都認為買受人根本就不是善意受讓，所以並不必要判斷是否構成民法第950條之公開交易場所。

¹¹² 該判決廢棄臺灣臺北地方法院95年度北簡字第11591號簡易民事判決。

否符合公開市場標準。第四小節研究，若買受人符合公開市場標準之其他要件，但乃以二手貨的價格購買舊品，是否應推定有重大過失。

表4 受讓人購物場所與主觀要素，
2006–2012年各級法院民事判決

購物場所	法院認定之主觀要素				總計
	善意無過失	善意重大過失	惡意	不論	
公開交易場所	0	1	0	0	1
販賣同類之商人	14	2	3	3	22
私下交易	14	2	11	1	28
不明	1	0	0	0	1
總計	29	5	14	4	52

資料來源：本文製表。請特別注意，本表中購物場所之分類，乃本文編碼時依據案件事實自行判斷；法院判決不總是涉及民法第950條，故多數判決並未判斷此議題。

（一）公開交易場所可以是買方開設

公開交易場所不一定非要賣方經營，買方才得到保護。公開交易場所之經營者若為買方（例如收購舊CD、舊唱片、古董的店），而賣方是（無權處分之）一般人，仍得適用公開市場標準。蓋無權處分之賣方仍會擔心，到公開交易市場上來賣，容易暴露行蹤。即使是現行民法第950條之構成要件文義，也沒有排除此種解釋之可能。所以，我國法院認為，當舖一概不屬公開交易場所，仍有再商榷餘地。再者，當舖業法第26條規定，「當舖業之負責人或其營業人員依本法規定收當之物品，經查明係贓物時，其物主得以質當金額贖回。當舖業之負責人或其營業人員非依本法規定收當之物品，經查明係贓物時，應無償發還原物主，原物主已先聲明贖回者，應將其贖回金額發還」。臺灣板橋地方法院101年度訴字第140號民事

判決，及其上訴審判決臺灣高等法院101年度上易字第649號民事判決¹¹³，認為當舖業法第26條屬於民法第950條之特別規定。但當舖業法第26條特別之處，僅在於要求當舖遵守標準收當流程，並按時向主管機關呈報。至於物主得以質當金額贖回部分，則與民法第950條規定一致——經營公開交易場所者，可以是買方！

荷蘭民法第3章第86條規定，專業買方無法享受盜贓物例外規則¹¹⁴，與本文見解略有不同。該規定應該是基於推定專業買方有較高辨識盜贓物之專業能力。但專業買方相對於一般零買的消費者，本來就有更強的誘因不要買盜贓物，因為專業買方之目標顯著，查獲容易；有些如當舖受到（高度）管制；商譽受損會因小失大。即令不管專業買方的誘因，給定善意受讓必須沒有重大過失，專業買方的專業知識，就可以在「重大過失」之判斷上排除有故意收贓嫌疑或胡亂收購的買方。荷蘭民法一律排除之規定，有簡省訴訟成本之優點，但也有膠柱鼓瑟的缺點。

（二）虛擬公開交易場所是否適格？

奧地利民法¹¹⁵與荷蘭民法¹¹⁶排除網路交易在公開交易場所之

113 該案中B性侵A，並強取A之住處鑰匙，至A之住處搜刮財貨，將其中一隻勞力士女錶典當於C當舖。法院指出當舖業法第26條，係民法第950條之特別規定。地方法院認為，C當舖依據當舖業法相關規定檢查物品、留下B之個人資料，屬於合法收當，故A必須支付C質當金額12萬元，才能取回該錶。

114 荷蘭民法第3章第86條規定：「...a natural person, not acting in the conduct of a profession or business, from an alienator whose business it is to deal with the public in similar things...」。

115 參見楊宏暉（註2），頁1804。

116 荷蘭民法下，要適用「公開市場規則」，必須買受人在有實體建築物之營業場所購買系爭標的物。參見同前註。荷蘭民法第3章第87條甚至規定，要適用公開市場規則，買受人必須能夠提供資訊，使出賣人得以被找到（“An acquirer, who is asked within three years from his acquisition to identify the alienator of the thing, must, without delay, provide all information necessary to trace that person or which, at the time of his acquisition, he could have considered as sufficient for that purpose. If he does not comply with this obligation, he may not invoke the protection which Article 86 and 86a afford to an acquirer in good faith.”）。這不啻使所有謹慎

範疇外，有其道理¹¹⁷。或謂，電子商務數量極大，日後只能增加不會減少，若眾多買賣在虛擬世界進行，卻不能適用善意取得規定，豈不是大大限縮善意取得制度之適用範圍？確實如此。但實施善意取得制度不是為了實踐制度本身，而是為了解決問題。

線上虛擬交易和線下實體交易，是非常不同的制度環境。不管是美國的Amazon、臺灣的PC Home購物、大陸的淘寶網，以及許許多多其他的電子商務交易平台，都已經因應虛擬交易的低資訊成本特徵，創造了虛擬交易獨有（或特別有效）的功能。例如按讚、評分、消費者評比等方式，讓消費者能在眾多素未謀面的賣家中，選擇口碑較佳者¹¹⁸，從而降低了消費者買到無權處分物之機率。而網路賣家為避免獲得不良評價，因為少數消費糾紛而喪失大量的未來交易機會，可能比實體賣家更注意篩選貨源，以免賣出盜贓物，產生消費糾紛等不良紀錄。此外，不少大型商務平台有履約保證機制¹¹⁹，讓消費者即令無法善意取得也能將損失降到最低。第三方支付工具如PayPal、支付寶等，逐漸成為虛擬交易的標準支付方式，

小心的荷蘭人必須保留收據或交易記錄三年，以免無法爰用公開市場規則。筆者好奇荷蘭法院實務如何詮釋本條，故以電子郵件詢問兩位荷蘭知名民法學者Sjev van Erp和Bram Akkermans。前者認為，一般而言，若買受人在刑事上沒有被認定為收受贓物，通常就會被認定為善意。雖然買受人不用保留收據，但必須能夠說明購買處。後者同樣強調能說明購買處之重要，並認為任何種類的交易記錄，即應足為證據。

117 有些網路交易仍以「面交」方式交付，買受人雖然需要事先提供第三方付款資訊，但在面交時檢驗系爭物若有質疑，仍有止付之機會。虛擬交易之態樣多元，且不斷演變。是否應該全面適用或不適用立法者為傳統店面交易設計的民法規則，恐怕需要另外以專文為之。

118 See generally Lior Jacob Strahilevitz, *Reputation Nation: Law in an Era of Ubiquitous Personal Information*, 102 NW. U. L. REV. 1667 (2008) (探討個人的名聲會如何在大數據年代被運用來衡量其可信賴度)。

119 例如，在YAHOO!拍賣服務網站，https://tw.bid.yahoo.com/help/new_auc/policy/protection.html（最後瀏覽日：2015年3月22日），若使用「YAHOO輕鬆付」，且符合其他條件（買到盜贓物有可能符合），買家最高可獲得伍萬元補償。此外，若使用「PC Home Pay支付連」，http://www.pchomepay.com.tw/security/stop_payment.html（最後瀏覽日：2015年3月22日），符合其他條件（買到盜贓物有可能符合），買家可能獲得「PC Home Pay支付連」退款。

而綁定銀行帳號等真實個人資料的第三方支付工具，使得賣方的身分容易查明與追蹤；因此，只想賺一票的雞鳴狗盜之徒，不太可能使用線上交易平台與第三方支付工具。就此而言，至少當消費者在高評價的網路賣家處消費時，碰上標的物為無權處分之機率非常低。因此，論者可能主張，可以套用前述以公開市場為構成要件的論據，使虛擬交易同樣適用善意取得制度。

然而，虛擬交易與實體交易的兩點不同，使得本文傾向不認為前者適合套用善意取得制度。第一，虛擬交易之買方往往無從檢查標的物，幾乎沒有花費徵信成本，也因此沒有值得保護之信賴。第二，如果虛擬交易適用善意取得制度，即網路世界到處都被認為是公開交易市場，則無權處分物可能會大量流入虛擬交易市場（因為暴露無權處分事實風險較低），無權處分可以在評價不高的賣家帳戶中，用假照片或其他虛假資訊，欺瞞買方。這使得本文倡議的善意取得制度中降低無權處分及引導受讓人購買行為的效果，蕩然無存。

另外一個重要原因是，至少在大型交易平台上，虛擬交易不需要善意取得制度。研究顯示，電子商務平台自己建立的線上爭議解決機制，無論是有效性或實際上的使用率都大大超過傳統的紛爭解決機制¹²⁰，而此種「內生的」線上紛爭解決機制，並不仰賴物權法的善意取得規定而解決問題。就此而言，它是網路世代的order without law（無關法律的秩序）——在Robert Ellickson以此命名的專書中，它描述了社會規範（social norm）如何和法律平行發展；換言之，法律規範之改變，並不影響社會規範之內容，而社群中人是依照社會規範行事，而非按照法律¹²¹。而自發的社會規範，可以

¹²⁰ 高薇，互聯網爭議解決的制度分析：兩種路徑及其社會嵌入問題，中外法學，2014年第4期，頁1071-1074（2014年）。

¹²¹ See generally ROBERT C. ELICKSON, ORDER WITHOUT LAW: HOW NEIGHBORS SETTLE DISPUTES (1991).

因網站而異的紛爭處理機制或實體規則，應該會比一體適用的民法規則，更可能達成效率。舉例而言，大型的網路平台，可以依據賣方是否有90%滿意度或1萬個讚，異其紛爭處理機制，誘使買方儘量選擇有信譽的廠商，降低糾紛的數量。但民法不可能制訂類似的規則。

以虛擬交易環境的低資訊成本，在線上交易不適用善意取得，或許有助於促進虛擬交易的分離均衡。亦即，在乎商譽，也確實小心篩選貨源的電子商務平台，可以提供履約保證補償等各種對消費有利之機制；其他廠商則不提供此種機制，或僅有較不優惠之替代制度。

（三）拍賣符合公開市場標準？

拍賣並未被現行民法列舉為買受人可受特別保護之交易方式。有學者認為，拍賣本質上須於公開場所為之，故自屬民法第950條之範疇；而拍賣無論是民法之拍賣（第391條規定、債編施行法第28條規定）、強制執行之拍賣或行政機關之標賣¹²²均同¹²³。

本文並不認為，凡是以拍賣形式出賣，均該當公開交易場所¹²⁴。民法第391條到第397條之拍賣，並沒有限定要公告周知，或

¹²² 例如地方政府拍賣報廢物品之惜物網，http://shwoo.gov.taipei/bid.asp?op_show&auid=148452（最後瀏覽日：2015年3月21日）；行政執行署拍賣公告，<http://www.tpk.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=52378&CtNode=14925&mp=030>（最後瀏覽日：2015年3月21日）；各地方法院檢察署也會拍賣扣押沒收物，參見如http://www.tcc.moj.gov.tw/lp.asp?CtNode=5544&CtUnit=71&BaseDSD=7&mp=015&xq_xCat=05（最後瀏覽日：2015年3月21日）。

¹²³ 參見謝在全，民法物權論（上冊），6版，頁499（2014年）。

而德國民法第935條的「公開」拍賣，則屬德國法下之例外情形。該條之拍賣，乃由法院執達員或其他公務員實施者，並非只要具有拍賣之形式，即可成為盜贓物規則之例外。參見Fritz Baur、Jürgen F. Baur、Rolf Stürner著，申衛星、王洪亮譯，德國物權法（下冊），頁430-431（2006年）；杜景林、盧謙，德國民法典評註——總則、債法、物權，頁186-187（2011年）。

¹²⁴ 許多公家機關主辦之拍賣，依法進行，根本不會有無權處分之虞，自然不在

在光天化日下公開進行。一個小偷在暗巷中，以拍賣方式將贓物出賣給兩個銷贓者中出價較高者，也是民法上的拍賣。但此種拍賣並不具備公開市場標準的經濟邏輯。再者，即使是大多數國人都熟知其存在的「法拍屋」，都往往乏人投標¹²⁵（當然跟不點交等不理想作法有關）。動產拍賣價格是否接近市價，似尚無研究，但可以想見會低於市價¹²⁶。準此，拍定人之經濟價值即較可能低於原所有人之經濟價值，從而不應偏向保護拍定人。

（四）以二手貨價格購買是否推定重大過失？

若某物（如單眼相機鏡頭）有蓬勃的新品市場，也有熱絡的二手市場，各自有市價（前者自然高於後者）。買受人在公開二手市場上，以舊品市場行情購得贓物鏡頭。此時應該保護原所有人或買受人？保護原所有人之論理是：買受人未買新品而買舊品，其願付價格應低於新品之市價。原所有人若曾以新品市價購入鏡頭，顯示其保留價格（經濟價值）等於或高於新品市價，從配置效率觀點，將鏡頭歸於原所有人較有效率。但是，若原所有人自己剛從二手市場上購入鏡頭，則原所有人與買受人孰為較能利用資源者，即難一概而論。相對地，保護買受人之理由則為上述之減少制度費用考量，以及簡單化善意取得規則（避免在公開市場標準下再開一種例外）。

善意取得問題討論之列。不過，許多此種機關之拍賣公告上都不忘加註「買受人對標之物無民法上之瑕疵擔保請求權」，其真意其實是不負「物之瑕疵擔保責任」，因為此種拍賣物均非新品，難以認定民法第354條之通常效用。但少了「物之」兩字，會讓似懂非懂者誤以為連權利瑕疵擔保請求權都沒有，進而誤會權利可能不存在，因而不願投標，導致成交價格無端降低。

¹²⁵ 參見張金鶚、王健安、陳憶茹，法拍屋折價之謎——市場競爭程度是否更能解釋折價？，交大管理學報，28卷2期，頁14（2008年）（2001到2002年間，46.6%的臺北市內的法拍屋，只有1人投標；而少人投標，正是法拍成交價格低於其他買賣方式成交價格之原因）。

¹²⁶ 關於不動產市場上，拍賣價格會低於談判銷售價格，see Yun-chien Chang & Lee Anne Fennell, *Appendices to Partition and Revelation*, 81 U. CHI. L. REV. DIALOGUE 1, 4-5 (2014).

兩相權衡之下，若對法院作出個案正確認定有信心，則不應採取斷然的構成要件，而讓法院在個案中有裁量空間。似乎不應一概將二手市場排除在公開交易場所之外，而可採取「未支付新品市價，推定為重大過失」之作法，使買受人有機會說明為何買二手貨及支付舊品市價是合理選擇。

四、公開市場標準與公開市場補償規則的選擇

上一節論證，應以公開市場標準作為善意取得制度之基石。本節進一步考量保護買受人之程度高低。換言之，應該讓買受人確定取得所有權，還是允許原所有人償還買受人支出之價金後取回系爭物？用前述Schwartz & Scott之用語，就是公開市場標準與公開市場補償規則之選擇。兩者差異又正好是財產原則之規則一（property rule; Rule 1）與補償原則之規則二（liability rule; Rule 2）間的選擇¹²⁷，差別在於是否給予原所有人買回標的物之選擇權（call option）。以下論述系爭物為替代物或非替代物，對制度選擇之影響。

（一）替代物

若系爭物是替代物，選擇公開市場補償規則有其道理。若能適用公開市場補償規則，必須買受人是善意，支付（高於）市價。原所有人願意用（高於）市價來贖回一個不是全新的替代物（還可能是第二次支付市價來取得該物），顯示了該物對其有特殊意義，因為其「主觀價值」（subjective value）¹²⁸高出市價。此外，若公開市

¹²⁷ 財產原則與補償原則之介紹，參見張永健（註7），頁201-205。

¹²⁸ 主觀價值，顧名思義，依個人主觀而不同。主觀價值是經濟價值（economic value）和公平市價（fair market value）之差。參見張永健，土地徵收補償之規範標準與實證評估，東吳法律學報，22卷4期，頁34（2011年）。See also Lawrence Blume & Daniel L. Rubinfeld, *Compensation for Takings: An Economic Analysis*, 72 CAL. L. REV. 569, 619 (1984); Fennell, *supra* note 49, at 963-65; THOMAS J. MICELI & KATHLEEN SEGERSON, THE ECONOMICS OF EMINENT DOMAIN:

場補償規則下之請求權時效同樣是兩年，則因時間尚短，買受人較不可能對系爭物產生高額主觀價值。換言之，原所有人可能是較能利用資源者。因而，讓原所有人有機會取回系爭物，有其道理。買受人因為獲得全額價金補償，縱有損失也不大，也可以用價金再去市場上另購可替代之物，不會太影響廣大潛在買受人之徵信程度。

另一種證立公開市場補償規則的取徑是行為法經濟學（behavioral law and economics），根據學者研究，因為訴訟中造成的彼此怨恨，以及法官判決造成的「稟賦效應」（endowment effect），使得當事人即使有利可圖都不會談判¹²⁹。若善意取得事件要通過法院裁決來解決，而當事人又無法在事前協商，則公開市場補償規則有助於克服稟賦效應與積怨的效應，因為原所有人毋須受讓人同意，即可付費取回系爭物。

（二）非替代物

如果是非替代物，則考量不同。當系爭物是非替代物時，買受人即使拿回了原所有人補償之價金，也在他處買不到替代品。非替代物往往沒有客觀市價（有行無市）；原所有人願意支付價金，也不一定代表其經濟價值¹³⁰（economic value）高於買受人之經濟價

PRIVATE PROPERTY, PUBLIC USE, AND JUST COMPENSATION 20 (2007).

¹²⁹ See Ward Farnsworth, *Do Parties to Nuisance Cases Bargain after Judgment? A Glimpse Inside the Cathedral*, 66 U. CHI. L. REV. 373 (1999). 對此研究發現之批評，參見Daphna Lewinsohn-Zamir, *The Choice Between Property Rules and Liability Rules Revisited: Critical Observations from Behavioral Studies*, 80 TEX. L. REV. 219, 232-33 (2001); RICHARD A. POSNER, *FRONTIERS OF LEGAL THEORY* 283-84 (2001); Peter H. Huang, *Reasons within Passions: Emotions and Intentions in Property Rights Bargaining*, 79 OR. L. REV. 435, 469 (2000); Ian Ayres & Kristin Madison, *Threatening Inefficient Performance of Injunctions and Contracts*, 148 U. PA. L. REV. 45, 52 (1999); Kyron Huigens, *Law, Economics, and the Skeleton of Value Fallacy: Behavioral Law and Economics Edited by Cass R. Sunstein*, 89 CAL. L. REV. 537, 555 (2001).

¹³⁰ 經濟價值之意義，參見張永健（註128），頁34；Blume & Rubinfeld, *supra* note 128, at 619; Fennell, *supra* note 49, at 963-65; MICELI & SEGERSON, *supra* note 128,

值。是以，此時應採用公開市場標準，而非公開市場補償規則。

（三）綜合分析

綜合上述分析，似以公開市場標準為原則，以公開市場補償原則為例外，而例外之條件為：（1）標的物是替代物，且（2）原所有人能證明標的物對其有特殊意義。

無論是現行法或本文建議制度，都不可能在每個個案中完美配置資源。若寇斯定理正確，而具體個案中的交易成本又低，則公開市場補償規則並無實益，因為原所有人和買受人可以在任何時候進行交易協商，使較能利用資源者，最終取得標的物之所有權。又若寇斯定理正確，但善意取得情境的交易成本通常很高，則公開市場補償規則有實益。不過，似乎沒有善意取得情境交易成本通常會特別高的堅強理由。因為有上述理論爭論，如果要證立公開市場補償規則之必要性，需要實證研究佐證¹³¹。

如果要在每個個案中都能確定配置資源無誤，則必須突破以立法規則擇定保護對象的模式，而以個案決定為之。個案決定不是法官依照兩造陳詞或個人心證決定，而是以「次價密封投標拍賣」（Second-price sealed-bid auction）方式，讓原所有人與受讓人彼此競標，以出價高低決定系爭動產歸屬。詳細制度設計方式，詳見另文¹³²。

at 20.

¹³¹ 筆者和林常青教授一篇英文的工作論文，即在以臺灣拆屋還地訴訟為對象，探究訴訟當事人在訴訟後是否會交易。簡言之，我們認為寇斯定理正確，訴訟當事人在訴訟後的交易，主要仍是受到理性考量的驅動。See Yun-chien Chang & Chang-Ching Lin, *Do Parties Negotiate after Trespass Litigation: An Empirical Study of Coasean Bargaining* (working paper, 2017), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2805063.

¹³² 參見張永健，民法典立法方法論——以《物權法》第106條、第107條動產所有權善意取得為例，財經法學，2017年第4期，頁64-66（2017年）。

五、善意重大過失之界定

善意若出於重大過失，不能善意取得，是舊法時代就有學者採取之立場¹³³。民法第948條之修法，使重大過失而不知的買受人，不能善意取得¹³⁴。然重大過失的善意該如何界定？第一小節以我國法院判決，具體說明法官在個案中之論理過程。第二小節則進一步以經濟分析方法，界定買受人之重大過失。第三小節主張，原所有人之重大過失，亦應納入權衡。

（一）判決中之具體推論

臺灣高雄地方法院98年度訴字第111號民事判決，上訴審臺灣高等法院高雄分院99年度上字第80號民事判決，再審臺灣高等法院高雄分院101年度再字第8號民事判決，具體探討中古堆高機買賣中，如何判斷買受人是否因重大過失而不知系爭堆高機為贓物，而且推論結果不同。原告甲至被告乙處購買該系爭堆高機，系爭之堆高機不在被告乙高雄之工廠，而在桃園之工地，由他人使用。第一審基於以下理由，認定原告甲就此300餘萬元之交易，其善意有重大過失：（1）乙未出具任何出借或出租之文件。（2）甲於買受交付前，未核對或詢問過任何系爭堆高機之文件或歸屬，只憑乙片面之詞就聽信。（3）甲未查證該堆高機是否在他人占有中。（4）所有文件包括讓渡書和進口文件都是事後給予。（5）甲於桃園看機器時，乙還表示該機器有糾紛，而甲不以為意。

第二審高等法院以下列論點，認定買受人甲為善意且沒有重大過失：（1）甲支付價金相當於（甚至高於）市價。（2）堆高機沒有

¹³³ 參見陳自強，民法第九百四十八條動產善意取得之檢討，收於：蘇永欽編，民法物權爭議問題研究，頁312（1999年）。

¹³⁴ 值得注意：臺灣高等法院高雄分院99年度上字第80號民事判決，認為民法第948條之修正（重大過失而不知亦不受善意取得保護），只是澄清，不是限縮善意之範圍。

登記制度，亦無從由警方查知系爭物是否為贓物。(3) 中古堆高機交易不一定會以「進口報單」作為權利證明，只會用「讓渡書」證明前手身分。(4) 甲、乙已有多次生意往來之互信基礎。(再審之訴駁回。)

臺灣苗栗地方法院100年度苗簡字第475號民事判決，上訴審臺灣苗栗地方法院101年度簡上字第39號民事判決，標的乃25公噸、樹齡50餘年之臺灣柚木。兩審均認為木材買受人非為善意，因為(如上訴審所論)「木材之價格與其產地在何處關聯甚大，則[買受人]應對於系爭柚木未砍伐前之情形加以瞭解，始行買受，方為合理，乃[買受人]僅與[出賣人]於電話對話即成立買賣系爭柚木之合意，未瞭解其產地、土地權利人如何，顯未為相當程度之查證，難謂[買受人]係[善¹³⁵]意買受系爭柚木。」

臺灣高等法院高雄分院99年度重上字第24號民事判決謂：「至該支扣押型鋼既印有[A公司]字樣，[B公司]抗辯其不知[A公司]所有為不可信。」

舊法時代雖然沒有區辨善意重大過失與惡意，但法院區別善意與惡意的推論過程，亦有值得參酌者：

臺灣南投地方法院97年度投簡字第646號民事簡易判決謂：「查一般民眾為使用桶裝瓦斯，須自行提供合格檢驗之瓦斯鋼瓶，或以租用方式或直接向瓦斯行買斷取得瓦斯鋼瓶，以利日後瓦斯之繼續使用，此為現一般桶裝瓦斯之販售方式。再消費者自瓦斯行取得鋼瓶後，因更換服務之瓦斯行，而將自他瓦斯行取得之鋼瓶轉交與之後提供瓦斯新業者，本非少見。而系爭瓦斯鋼瓶係於87年6月22日經法院公證，迄原告所稱97年10月6日發現系爭鋼瓶時，已逾10年，其間系爭瓦斯鋼瓶因消費者之任意處分，多方流轉於瓦斯業者

135 判決書漏繕「善」字，但從上下文可作此推定。

之間本屬可能，且原告於系爭瓦斯鋼瓶製作之『N』之商標及編號，並非一般人皆可週知之公示方法，則被告辯稱自消費者處取得系爭鋼瓶時，無從辨別屬原告所有，即屬可採。」

臺灣高等法院96年度上易字第505號民事判決中，所有人之汽車遭人使用偽造之執照等證件申請補發牌照登記書，並持之辦理過戶登記，並以此辦理汽車貸款辦理動產抵押設定登記。所有人請求塗銷動產抵押登記，法院判定主張善意取得抵押權之人，因其對保程序僅就該車輛之外觀與登記資料進行核對，並未依汽車貸款業務人員報告書之要求，確實核對該車輛之引擎號碼是否與登記資料相符，故無法認定持相關證件辦理本件抵押貸款之人確係占有系爭汽車，故無法主張善意取得。

臺灣臺北地方法院94年度訴字第1787號民事判決則交融了當舖收當方式與買受人善意或惡意之判斷。本件標的為汽車。法院認為，A當舖於收當時須查核持當人之身分證件及系爭車輛登記證明文件，或以簡便方式（如電話）向車主或監理機關查詢。A當舖因未查核，難依當舖業法第21條規定，於當期屆滿後，當戶不取贖時，取得收當車輛之所有權。A當舖賣車給B，變成無權處分。法院認為，B雖稱其以118萬元購買系爭車輛，然未提出相關付款資料以資證明，與一般買賣交易過程迥異；且B購買系爭車輛，就顯而易見之系爭車輛屬租賃車及其行車執照載車主為Z，未提出任何質疑；亦未請當舖提供相關質當登載資料以供查詢；甚且於買受後2年多以來，未辦理過戶登記，更與常情有違。故B也未善意取得。B再賣給C，C受讓系爭車輛當時，行車執照早已逾期失效，而且於受讓後，未辦理過戶，未請領牌照行駛，而改懸掛其他車牌，與常情有違；又未能出具付款證明，而其所稱之購買款項與市價相比顯然較低。故C亦未善意取得所有權。

案件事實最離奇者，當屬臺灣臺南地方法院94年度重訴字第56

號民事判決，及其上訴審及更審：臺灣高等法院臺南分院95年度重上字第56號民事判決、臺灣高等法院臺南分院97年度重上更（一）字第11號民事判決、臺灣高等法院臺南分院99年度重上更（二）字第9號民事判決。系爭標的為高雄縣甲仙鄉國有土地上46,588.32立方公尺砂石！各判決均認定買受人未善意取得，因為買受人係以公證書代替實質交付（即未從出賣人處取得占有），且買受人買賣當時明知出賣人採取土石之期限早於十餘年前屆滿，且系爭砂石堆置於河川公地上至少已有數年之久。

（二）買受人「可得而知」之判定¹³⁶

判決中展現的豐富事實，固然有助於刺激想像力、擴展視野，但有難以外推的缺點。對於面對新案件事實之法官，應該以何種抽象標準、思考步驟，判斷買受人是否有重大過失？

經濟分析文獻中有區分good faith（善意）和innocence（無知）¹³⁷，用我國法的術語，前者是無重大過失之善意，後者是有重大過失之善意。從經濟分析理論，買受人要構成可受善意取得制度保護之善意，必須買受人已付出「最適的資訊投資」，而仍認為出賣人有權處分之機率相當高¹³⁸。抽象地說，買受人付出之徵信成本，必須高於或等於徵信所引致的預期社會利益。更具體一點，法

¹³⁶ 在善意取得之討論中，常假設無權處分人消失無蹤，所以法律才要在兩個無辜的人當中挑一個保護。如果無權處分人還找得到，也仍有資力，在現行民法第351條下，可得而知（但非明知）之買受人可要求無權處分人擔負權利瑕疵擔保責任。關於買賣之權利瑕疵擔保，參見黃茂榮，買賣法，5版，頁576（2002年）。

¹³⁷ See Landes & Posner, *supra* note 91, at 192-93.

¹³⁸ See *id.* at 190-91（有兩種情形是無知而非善意：1. 無權處分的機率高；2. 無權處分的機率*標的物價值>受讓人實際支出之徵信成本）。

請注意Landes & Posner也承認，其提出之判斷標準只能處理資訊投資是否對個人而言最適，但不當然是對社會而言最適（socially optimal）。See *id.* at 190 n.21. 對社會而言最適的資訊投資很難提出精準的公式，因為難以知悉每個買受人個人的徵信如何程度內降低了出賣人的無權處分誘因。

官可以判斷，標的物售價是否低於新品合理市價太多？若價格明顯過低，買受人懷疑標的物來歷不明，從而詢問、質疑出賣人之徵信成本就很低¹³⁹。買受人若是專業採購者，通常徵信成本較低。在標的物性質不特別適合（或業內交易習慣沒有採取）指示交付或占有改定，而出賣人提出或堅持使用此種觀念交付方式時，買受人應該會產生合理懷疑，進而徵信。所以，若價格顯著低於市價、買受人以收購同類物為業、擬制交付之選擇不合常理，買受人是善意有重大過失的可能性上升¹⁴⁰。

新民法第948條使用「重大過失」一詞作為排除善意買受人取得物權之條件。本文認為，善意買受人之不受保護，源自於其應取得資訊（系爭物係被無權處分）而未取得¹⁴¹。而此種疏未獲得資訊之行為，使用（民法第826條之1等條有使用之）「可得而知」，更為準確¹⁴²。「（重大）過失」一詞，使用於小心、防範程度，方能適切凸顯兩者本質之不同——下小節關於原所有人防止無權處分之過失，即為一例。

而無論使用可得而知或重大過失，都要進一步定性為主觀標準或客觀標準。民法學說實務上向來只有對輕過失區分具體輕過失（主觀標準）與抽象輕過失（客觀標準），而未系統性地將重大過失

139 See *id.* at 217. 參見楊宏暉（註2），頁1795。在中國物權法第106條第1項第2款，以合理價格轉讓，是善意取得之要件，亦為類似作法。

140 類似見解，參見謝哲勝（註87），頁499。

141 越界建築情境中的越界者是否出於重大過失，與此問題之本質十分類似。相關經濟分析，參見張永健，越界建築之經濟分析，中研院法學期刊，12期，頁169-170（2013年）。因此，民法第796條、第796條之1的故意和重大過失，都應該修正為明知與可得而知。其他物權編使用故意、（重大）過失的條文，也有應該改為明知、可得而知者，並稍作文字調整，如民法第881條、第899條。至於民法第782條、第820條、第922條使用之故意、過失，與造成損害或滅失有關，與是否擁有或應取得資訊無關，則可維持此種用詞。

142 為整合歐洲私法所提出之Draft Common Frame of Reference (DCFR)的VIII.-3:101規範善意取得之條件時，就使用“could reasonably be expected to know”為要件，與「可得而知」一詞可作同樣理解。

也區分為具體重大過失與抽象重大過失，雖在理論上並無不可。一般多將重大過失認定為客觀標準，以普通人之注意為準¹⁴³。此又有民法第223條「應與處理自己事務為同一注意者，如有重大過失，仍應負責」為據。不過，已有學者指出，民法中「過失」之功能不一，無庸一律作同樣解釋¹⁴⁴，否則反而有害立法目的之達成。此外，民法債編之定義，不當然要用於物權編。誠然，從體系解釋出發，凡稱為重大過失一律以同樣方式解釋，有其道理。但從目的解釋出發，民法第948條之重大過失應該是主觀標準——如上所論，專業買家比較能夠判別系爭物是否可能為無權處分物，一般消費者則否。若兩者要適用同樣的重大過失標準，不是讓專業買家可以偷懶、便宜行事，就是課予消費者過重的責任。想要不兩害相權，依照本文主張，將民法第948條之重大過失修正為可得而知，即可避免困擾。但無論採用何種名詞，從效率觀點，買受人之善意均須以已獲取適當權利歸屬資訊為要件。

但若立法者果真將民法第948條之重大過失修正為可得而知，是否加重了受讓人之獲取資訊義務？本文不作如是想。如前所論，故意和明知、過失和可得而知，不應該各自被相提並論。明知和可得而知這組概念，描述的就是當事人是否具有某種資訊，或是否可以輕易獲得某種資訊。這和例如侵權法上的過失，關注的是防範程度或注意義務程度，功能不同，性質不同。從經濟分析出發的解釋論，會將民法第948條之重大過失，解釋為未盡合理資訊蒐集；從經濟分析出發的解釋論，會建議將修正之民法第948條之可得而知，作同樣解釋。因此，本文提倡之修正，並不會修正或改變受讓人實際上應該負擔的資訊獲取義務。

143 參見例如邱聰智著，姚志明修訂（註80），頁23-24。

144 參見張永健，購物網站標錯價之合約糾紛與行政管制——經濟分析觀點，政大法學評論，144期，頁175-177（2016年）。

此外，由於多數動產的產權歸屬不容易判定，本文贊同現行法將一般買受人推定為善意且非可得而知¹⁴⁵。

(三) 原所有人重大過失

1. 為何要求原所有人不得有重大過失

原所有人如果未善盡防範之責，導致其物被他人無權處分，不應賦予其返還請求權¹⁴⁶。原所有人若能付出合理成本，離家鎖門、疑人不用、行事謹慎，就不會掉東西。沒有無權處分事件，就不用動用警察、檢察官、法院等納稅人大幅補貼的公共財。直白地說，原占有人沒來由地將全新Apple Watch遺忘在酒吧，或者住在臺北市但以為身處大同世界而夜不閉戶，導致全家被偷光；在民法第949條的構成要件底下，這樣的原占有人仍比善意買受人更受保護，有道理嗎？所以，從事前觀點，若不論原所有人是小心謹慎還是粗枝大葉，都一律可以動用寶貴的法律體系資源，進而干擾善意非可得而知之買受人對系爭物之利用，並非最佳誘因機制。但必須注意，規定原所有人要無重大過失地保護自己的所有物，從事前觀點，不會改變許多人的行為；因為多數人多數時候，都已經用更強的注意程度，保護自己的財產。準此，剝奪重大過失原所有人的返還請求權，旨在追求改變少數特別粗心者的行為，也只會影響到這種人的返還請求權。

從事後觀點設想，不保護有故意或重大過失的所有人，有額外的經濟意義。第一種切入角度是，如果規定有重大過失的所有人，

¹⁴⁵ DCFR VIII-3:101未作此推定，受到學者批評，認為原所有人因為難以確定買受人是否能成功舉證其善意，故更願意興訟，從而增加善意取得訴訟量。See Salomons, *supra* note 87, at 855.

¹⁴⁶ Draft Common Frame of Reference的VIII-3:101之Comment D說明，遺失物與盜贓物區別處理，是因為遺失物被無權處分，導因於原所有人之過失。由此可知，DCFR之撰寫者，也隱然將原所有人之過失納入考量。但是，東西被偷，有時也是原所有人過失所致。DCFR之撰寫者並未考量此點。

不得請求返還，則此種原所有人遇上無權處分，就自認倒楣，免除後續警察、法院等制度成本。但是，有重大過失的原所有人不可能因為此種規定就當然放棄追索，因為無權處分人可能尚未完成處分，受讓人也可能並非善意，而警察的調查成本不用原所有人負擔。是故，有重大過失的原所有人還是會繼續追索。所以，此種切入角度，無法證立排除有重大過失之原所有人請求返還。

第二種切入角度是，事後比較個案當事人之保留價格。在天秤上被比較的兩造，一個是有重大過失原所有人，一個是在非公開市場付出市價購買系爭物、不得而知的受讓人，兩者都（至少曾經）有高於市價的願受價格。但或許原所有人以重大過失方式防範自己的系爭財產，顯示了他的願受價格或許已經降低，才會疏於防範。因此，受讓人比較有可能是較能利用資源的一方。

綜上所論，制度設計上，可以考慮作如下設計：受讓人「不得而知+非公開市場」，可以在原所有人有重大過失時，使受讓人保有系爭物；而受讓人「可得而知+公開市場」時，原所有人有重大過失，不使原所有人喪失返還請求權。換言之，對受讓人取得所有權而言，其「不得而知」比「在公開市場進行交易」更為重要。原因在於，公開市場只是輔助判斷受讓人是否支付市價的「代理變數」（proxy）。在本文制度下，受讓人如果可以舉證成功自己是不得而知（至少必須證明自己支付市價），公開市場要件不備，僅有次要意義，因為此時受讓人的願付價格是大於或等於市價。

或有質疑，原所有人不得犯重大過失，是課予其對己義務。本文回應是：單單課予對己義務本身，不足以挑戰本文主張；而需要說明課予對己義務為何不合理。對己義務在法律規定在屢見不鮮。民法第796條要求被越界者必須即時異議，否則不得要求越界者拆

除越界物¹⁴⁷。消滅時效制度也可以看成是一種對己義務¹⁴⁸。保險法第58條、第59條、第63條也課予要保人即時通知之義務。要求原所有人不得故意或重大過失使其物被無權處分，按照上文之解釋，是絕大多數物權人本來就會做的。在權衡善意買受人與原所有人，以原所有人善盡合理防範作為選擇保護其之要件，應屬合理。

2. 如何在個案中界定重大過失

重大過失的界定方式，可以參考「漢德公式」(Hand formula)¹⁴⁹，比較原所有人之「防範成本」與「防範所能降低之無權處分機率*無權處分造成之損失」¹⁵⁰。前者低於後者，原所有人有過失。再比較原所有人實際的防範措施與可行的額外防範措施；若一單位的額外防範措施可以大幅降低預期損失，則原所有人有重大過失。

此處仍有重大過失為主觀或客觀標準之問題。本文傾向主觀標準。事實上，漢德公式本身必然是（以客觀證據推測之）主觀標準¹⁵¹，因為每個人的防範成本、防範所能降低之無權處分機率都不

147 實務上對越界建築即時異議規定之解釋方式，參見張永健，越界建築訴訟之實證研究，中研院法學期刊，14期，頁335-338（2014年）。

148 消滅時效問題之經濟分析，參見簡資修，消滅時效的證據衰竭不等說，中研院法學期刊，6期，頁129-166（2010年）。

149 See RICHARD A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 213-18 (8th ed. 2011). 中文文獻，參見王澤鑑（註70），頁311-313；簡資修，經濟推理與法律，頁199-201（2014年）。

150 表2依據現行法的架構，分類2006-2012年的判決。各該判決中的原所有人，是否有重大過失，則需要逐一檢視案件事實後判斷。在缺乏原始卷宗的局限下，筆者很難在法院根本沒有作原所有人是否重大過失的條件下，事後諸葛一番。但須說明者，各原所有人是否有重大過失，不應僅以該表的法律關係分類而判斷。舉例而言，固然強盜事件的被害人，多半沒有重大過失，但仍可想像有夜行暗巷、錢財露白、對旁人善意勸告置之不理，然後被強盜者。而委託他人保管之情形，固然許多時候是倒楣碰到受託人生平第一次惡向膽邊生，也可以想像有受託人是舉世知名的騙徒，但委託人仍對其深信不疑。

151 參見簡資修，侵權行為的私法性質，將刊於：北大法律評論，2016年第1期（2016年）。

盡相同。但因為法官不是全知全能，即使採取主觀標準，法官往往必須依照其對普通人的推測或認識出發，推斷成本與機率之高低，再依據原所有人之狀況而調整¹⁵²。就此而言，主觀與客觀標準在實際實務操作上，或許也沒有這麼大區別。

當然，在構成要件上增加一項「原所有人重大過失」，尤其採取主觀標準說時，必然增加訴訟成本。成本效益分析必須兼籌併顧，增加訴訟成本不好，但不課予原所有人善盡保管職責的誘因也不好。本文認為，若要兩者取得平衡，或許法院可以由常情常理出發，僅在原所有人過度偏離理性合理人（普通人）標準時（例如出國遊玩不但不鎖門，連門都不關），才論其為重大過失，而其個人防範成本與機率之特殊性容易探知時才納入考量，應不至於增加太多訴訟耗費。

伍、結論

本文主張，以配置效率與生產效率為經濟理由，決定在原所有人與善意受讓人間，選擇保護哪一方。具體言之，符合公開市場標準之交易，善意無重大過失之受讓人可以取得所有權，但在標的物為替代物且對原所有人有重大意義時，例外讓原所有人可以支付價款後取回。不符合公開市場標準之交易，不構成善意取得，處分效力未定。嚇阻竊盜應該由侵權行為法與刑法負責，善意取得制度設計不用考慮。

¹⁵² 最近有學者探討「量身定作」過失標準，考量效率與公平兩種價值後，其結論是，降低較有防範能力者的過失標準，使其負擔更多防範責任，是可欲結果。但增加較無能力防範者的過失標準，使其負擔較少防範責任，則理由較為薄弱。此見解亦可納入制度設計考量。See Omri Ben-Shahar & Ariel Porat, *Personalizing Negligence Law*, 91 N.Y.U. L. REV. 627 (2016).

善意取得經濟分析文獻，最新、最重要者為Schwartz & Scott之大作。本文結論與其結論之異同如下：

(1) Schwartz & Scott認為，若原所有人對物被無權處分並無過失，則有權向善意買受人要求返還。本文認為，若原所有人無重大過失，但受讓人之買賣符合公開市場標準，且受讓人不得而知，則原所有人不得無償請求回復。原所有人至多在符合正文所述條件下，支付償金後回復。若買賣不符合公開市場標準，且受讓人可得而知，無重大過失之原所有人可以請求返還，自屬當然。若買賣不符合公開市場標準，但受讓人不得而知，因未完全符合善意取得要件，轉讓效力未定，無重大過失之原所有人自可請求返還。

(2) Schwartz & Scott認為，若原所有人有過失，買受人無過失（即本文之不得而知），則前者不得要求後者返還。本文認為，較有實益的討論情境是：買賣不符合公開市場標準，但買受人不得而知，此時原所有人又有重大過失。按照本文簡單的善意取得架構，此時因為沒有完全符合善意取得之要件，讓與之效力未定。原本所有人應該可以行使其物上請求權，但此時例外課予原所有人對己義務，使有重大過失之原所有人，不得請求返還——本文無意課予原所有人過重之對己義務，法院解釋原所有人之重大過失時需保守謹慎。

(3) Schwartz & Scott認為，若兩造皆有（重大）過失，則原所有人仍可要求買受人返還。本文同意，因為有重大過失之買受人自始不受善意取得制度保護。

若立法者決定純以效率為依歸（或者，公平、正義的分析結果，並不認為在本文提出的制度與現行制度間，後者必然較優），重新制訂善意取得制度，依本文提出之分析架構，民法相關條文可考慮修正如下：

民法第948條改為：「I以動產所有權之移轉為目的，於公開交易場所，或由販賣與其物同種之物之商人，善意受讓該動產之占有者，縱其讓與人無讓與之權利，仍取得所有權。但受讓人可得而知讓與人無讓與之權利者，不在此限。II受讓人未支付該動產新品之合理市價，或該動產為可登記者，推定為可得而知。III非由實體店面獲得該物者，推定為非公開交易場所。」

民法第949條改為：「前條第一項動產係替代物且對原所有人有特殊意義者，原所有人自喪失占有之時起二年以內，得償還受讓人支出之價金，回復其物。」

民法第950條改為：「原所有人對無權處分有重大過失者，不得向善意且非可得而知而受讓之現占有人請求回復其物。」

民法第951條改為：「前二條之物如係金錢或未記載權利人之有價證券，不得向其善意受讓之現所有人請求回復。」

民法第951條之1刪除。

民法第801條刪除。且上列條文應考慮移至民法第761條及第762條之間，以彰顯善意取得為透過交易、例外取得動產所有權之方式。質權善意取得之規定，應可用類似方式修正，但仍須另文詳加分析。

民法第953條到第959條的所有人占有人關係，原本在體系上以動產未善意取得為前提，是仿自瑞士法之設計¹⁵³。在前述條文搬動後，會有一定的體系割裂。筆者對民法第953條到第959條之規範，亦有立法論建議，以解決這些規範本身實體內容問題與體系問題。然此須嗣諸後文，請方家先進繼續收看。

¹⁵³ 蘇永欽，所有人與占有人關係，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁327-328（2001年）。

參考文獻

1. 中文部分

Fritz Baur、Jürgen F. Baur、Rolf Stürner著，申衛星、王洪亮譯（2006），德國物權法（下冊），北京：法律出版社。[Baur, Fritz/Baur, Jürgen F./Stürner, Rolf (1999), Sachenrecht, 17. Aufl., München: C. H. Beck.]

王澤鑑（1979），盜賊物之牙保、故買與共同侵權行為，收於：民法學說與判例研究（二），頁225-238，臺北：自版。

——（2009），侵權行為法，臺北：自版。

——（2010），民法物權，2版，臺北：自版。

王鵬翔、張永健（2016），被誤解的戀情——經濟分析與法學方法，2016法律思想與社會變遷學術研討會：經濟分析與法學方法，中央研究院法律學研究所主辦，2016年11月10日。

吳光明（2007），善意取得制度之設計與省思，財產法暨經濟法，11期，頁1-33。

杜景林、盧諶（2011），德國民法典評註——總則、債法、物權，北京：法律出版社。

林俊廷（2014），論物之經濟效用解釋——案例事實之類型化分析，收於：司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集編輯委員會編，物權與民事法新思維：司法院謝前副院長在全七秩祝壽論文集，頁463-486，臺北：元照。

林誠二（2007），債權人行使代位權之要件與限制，月旦法學教室，60期，頁8-9。

邱聰智著，姚志明修訂（2014），新訂民法債編通則（下冊），新訂2版，臺北：自版。

孫森焱（2010），民法債編總論（下冊），99年5月版，臺北：自

版。

高薇（2014），互聯網爭議解決的制度分析：兩種路徑及其社會嵌入問題，中外法學，2014年第4期，頁1059-1079。

崔建遠（2011），物權：規範與學說——以中國物權法的解釋論為中心（上冊），北京：清華大學出版社。

張永健（2001），論動產善意取得之若干問題，台灣本土法學雜誌，27期，頁105-120。

——（2011），土地徵收補償之規範標準與實證評估，東吳法律學報，22卷4期，頁27-64。

——（2012），法定通行權之經濟分析，臺大法學論叢，41卷特刊，頁1321-1372。

——（2013），占有規範之法理分析，臺大法學論叢，42卷特刊，頁847-932。

——（2013），越界建築之經濟分析，中研院法學期刊，12期，頁153-201。

——（2014），物權法之經濟分析導論（一）——事前觀點與交易成本，月旦法學雜誌，230期，頁248-260。

——（2014），物權法之經濟分析導論（二）——效率，月旦法學雜誌，231期，頁194-205。

——（2014），越界建築訴訟之實證研究，中研院法學期刊，14期，頁319-373。

——（2015），張五常《經濟解釋》對法律經濟學方法論之啟示，交大法學，總第13期，頁27-36。

——（2016），歷久彌新或不合時宜？——民法不動產時效取得制度之實踐與革新，中研院法學期刊，18期，頁195-266。

——（2016），購物網站標錯價之合約糾紛與行政管制——經濟分析觀點，政大法學評論，144期，頁155-225。

——（2017），民法典立法方法論——以《物權法》第106條、第107條動產所有權善意取得為例，財經法學，2017年第4期，頁

50-67。

張金鶚、王健安、陳憶茹(2008)，法拍屋折價之謎——市場競爭程度是否更能解釋折價？，交大管理學報，28卷2期，頁1-39。

陳自強(1999)，民法第九百四十八條動產善意取得之檢討，收於：蘇永欽編，民法物權爭議問題研究，頁301-314，臺北：五南。

陳忠五(2011)，2010年民事法發展回顧，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1699-1756。

陳添輝(2007)，是否得以占有改定之方式善意取得動產所有權？，法令月刊，58卷12期，頁35-46。

——(2015)，動產善意取得制度之起源及發展，法令月刊，66卷8期，頁1127-1158。

陳榮傳(2014)，民法物權實用要義，臺北：五南。

游進發(2010)，占有本權與事實推定，法學叢刊，55卷3期，頁71-97。

黃茂榮(2002)，買賣法，5版，臺北：自版。

——(2010)，債法總論(三)，3版，臺北：自版。

楊宏暉(2012)，動產所有權善意取得制度之比較與再檢討，臺大法學論叢，41卷4期，頁1743-1818。

溫豐文(2007)，占有改定與善意取得，台灣法學雜誌，99期，頁188-190。

劉宗榮(2003)，論對盜賊遺失物善意受讓人行使回復請求權之主體及其法律效果，月旦法學雜誌，100期，頁32-41。

——(2010)，論所有權安全的保護與交易安全的保護，月旦法學雜誌，187期，頁59-69。

鄭玉山(2009)，占有改定、指示交付與善意取得——自受讓占有外觀之省思，台灣法學雜誌，134期，頁21-76。

鄭冠宇(2000)，民法物權編修正系列研討會之三——占有的相關

法律問題之探討，月旦法學雜誌，66期，頁107-133。

謝在全（1988），論動產所有權善意取得，法令月刊，39卷2期，頁10-16。

——（2009），民法物權論（下冊），4版，臺北：自版。

——（2014），民法物權論（上冊），6版，臺北：自版。

謝哲勝（2009），無償受讓可否主張善意受讓，月旦法學教室，86期，頁14-15。

——（2012），民法物權，4版，臺北：三民。

謝哲勝、莊春發、黃健彰、邵慶平、張心悌、楊智傑（2007），法律經濟學，臺北：五南。

簡資修（2010），消滅時效的證據衰竭不等說，中研院法學期刊，6期，頁129-166。

——（2014），經濟推理與法律，臺北：元照。

——（2016），侵權行為的私法性質，將刊於：北大法律評論，2016年第1期。

蘇永欽（1983），動產善意取得若干問題，法學叢刊，112期，頁49-63。

——（1999），善意受讓盜贓物可否即時取得？，收於：蘇永欽編，民法物權爭議問題研究，頁315-324，臺北：五南。

——（2001），所有人與占有人關係，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁323-337，臺北：五南。

——（2001），動產所有權的代理取得，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁37-54，臺北：五南。

——（2001），盜贓物善意取得，收於：蘇永欽編，民法物權實例問題分析，頁307-321，臺北：五南。

2. 外文部分

Alexander, Gregory S., and Eduardo M. Peñalver. 2012. *An Introduction to Property Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Ayres, Ian, and Kristin Madison. 1999. Threatening Inefficient Performance of Injunctions and Contracts. *University of Pennsylvania Law Review* 148:45-108.
- Baird, Douglas G., Robert H. Gertner, and Randal C. Picker. 1998. *Game Theory and the Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bebchuk, Lucian Arye. 2001. Property Rights and Liability Rules: The Ex Ante View of the Cathedral. *Michigan Law Review* 100:601-639.
- Ben-Shahar, Omri. 1997. Property Rights in Stolen Goods: An Economic Analysis. Working paper. Available at https://pdfs.semanticscholar.org/735b/19c087829d01c3facf3b817c904a9637f960.pdf?_ga=2.148236530.436016872.1502019499-294750090.1502019499.
- Ben-Shahar, Omri, and Ariel Porat. 2016. Personalizing Negligence Law. *New York University Law Review* 91:627-688.
- Blume, Lawrence, and Daniel L. Rubinfeld. 1984. Compensation for Takings: An Economic Analysis. *California Law Review* 72:569-628.
- Brooks, Richard R.W., and Warren F. Schwartz. 2005. Legal Uncertainty, Economic Efficiency, and the Preliminary Injunction Doctrine. *Stanford Law Review* 58:381-410.
- Chang, Yun-chien, and Chang-Ching Lin. 2017. Do Parties Negotiate after Trespass Litigation: An Empirical Study of Coasean Bargaining. Working paper. Available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2805063.
- Chang, Yun-chien, and Lee Anne Fennell. 2014. Appendices to Partition and Revelation. *University of Chicago Law Review Dialogue* 81:1-13.
- Cooter, Robert, and Thomas Ulen. 2012. *Law and Economics*. 6th ed. Boston, MA: Pearson/Addison Wesley.
- Dari-Mattiacci, Giuseppe, and Carmine Guerriero. 2015. Law and

- Culture: A Theory of Comparative Variation in Bona Fide Purchase Rules. *Oxford Journal of Legal Studies* 35:543-574.
- Demsetz, Harold. 2008. *From Economic Man to Economic System: Essays on Human Behavior and the Institutions of Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eisenberg, Theodore. 1990. Testing the Selection Effect: A New Theoretical Framework with Empirical Tests. *The Journal of Legal Studies* 19:337-358.
- Ellickson, Robert C. 1991. *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Epstein, Richard A. 1994. On the Optimal Mix of Private and Common Property. *Social Philosophy and Policy* 11:17-41.
- Farnsworth, Ward. 1999. Do Parties to Nuisance Cases Bargain after Judgment? A Glimpse Inside the Cathedral. *The University of Chicago Law Review* 66:373-436.
- Fennell, Lee Anne. 2004. Taking Eminent Domain Apart. *Michigan State Law Review* 2004:957-1004.
- . 2013. The Problem of Resource Access. *Harvard Law Review* 126:1471-1531.
- Huang, Peter H. 2000. Reasons within Passions: Emotions and Intentions in Property Rights Bargaining. *Oregon Law Review* 79:435-478.
- Huigens, Kyron. 2001. Law, Economics, and the Skeleton of Value Fallacy: Behavioral Law and Economics Edited by Cass R. Sunstein. *California Law Review* 89:537-568.
- Kahneman, Daniel. 2011. *Thinking, Fast and Slow*. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Klerman, Daniel. 2015. Jurisdiction, Choice of Law, and Property. Pp. 266-289 in *Law and Economics of Possession*, edited by Yun-chien

- Chang. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koo, Hui-wen. 2011. Property Rights, Land Prices, and Investment: A Study of the Taiwanese Land Registration System. *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 167:515-535.
- Landes, William M., and Richard A. Posner. 1996. The Economics of Legal Disputes over the Ownership of Works of Art and Other Collectibles. Pp. 177-219 in *Economics of the Arts: Selected Essays*, edited by Victor Ginsburgh and Pierre-Michel Menger. Bruxelles: Universite Libre de Bruxelles.
- Lee, Yoon-Ho Alex, and Daniel Klerman. 2016. The Priest-Klein Hypotheses: Proofs and Generality. *International Review of Law and Economics* 48:59-76.
- Levmore, Saul. 1987. Variety and Uniformity in the Treatment of the Good-faith Purchaser. *The Journal of Legal Studies* 16:43-65.
- Lewinsohn-Zamir, Daphna. 2001. The Choice Between Property Rules and Liability Rules Revisited: Critical Observations from Behavioral Studies. *Texas Law Review* 80:219-260.
- Mackaay, Ejan. 2013. *Law and Economics for Civil Law Systems*. Northampton, MA: Edward Elgar.
- Medina, Barak. 2003. Augmenting the Value of Ownership by Protecting It Only Partially: The “Market-Overt” Rule Revisited. *The Journal of Law, Economics, and Organization* 19:343-372.
- Merrill, Thomas W. 2002. Incomplete Compensation for Takings Regulatory Expropriations in International Law. *New York University Environmental Law Journal* 11:110-135.
- . 2009. Accession and Original Ownership. *Journal of Legal Analysis* 1:459-510.
- Miceli, Thomas J., and Kathleen Segerson. 2007. *The Economics of Eminent Domain: Private Property, Public Use, and Just*

- Compensation*. Boston, MA: Now Publishers.
- Posner, Richard A. 2001. *Frontiers of Legal Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . 2011. *Economic Analysis of Law*. 8th ed. New York, NY: Aspen.
- Priest, George L., and Benjamin Klein. 1984. The Selection of Disputes for Litigation. *The Journal of Legal Studies* 13:1-55.
- Rose, Caspar. 2010. The Transfer of Property Rights by Theft: An Economic Analysis. *European Journal of Law and Economics* 30:247-266.
- Salomons, Arthur F. 2009. On the Economics of Good Faith Acquisition Protection in the DCFR. Pp. 199-216 in *The Politics of the Draft Common Frame of Reference*, edited by Alessandro Somma. New York, NY: Wolters Kluwer.
- . 2011. Good Faith Acquisition of Movables. Pp. 1065-1082 in *Towards a European Civil Code*, 4th ed., edited by Arthur S. Hartkamp, Martijn W. Hesselink, Ewoud H. Hondius, Chantal Mak, and C. Edgar du Perron. The Hague: Wolters Kluwer.
- . 2013. The Purpose and Coherence of the Rules on Good Faith Acquisition and Acquisitive Prescription in the Draft Common Frame of Reference: A Tale of Two Gatekeepers. *European Review of Private Law* 21:843-862.
- Schäfer, Hans-Bernd, and Claus Ott. 2004. *The Economic Analysis of Civil Law*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Schwartz, Alan, and Robert E. Scott. 2011. Rethinking the Laws of Good Faith Purchase. *Columbia Law Review* 111:1332-1384.
- Shavell, Steven. 2004. *Foundations of Economic Analysis of Law*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Smith, Henry E. 2009. Law and Economics: Realism or Democracy?. *Harvard Journal of Law & Public Policy* 32:127-145.

Strahilevitz, Lior Jacob. 2008. Reputation Nation: Law in an Era of Ubiquitous Personal Information. *Northwestern University Law Review* 102:1667-1738.

An Economic Analysis of Good-faith Purchase of Chattels

*Yun-chien Chang**

Abstract

The good-faith purchase doctrine varies a lot across common- and civil-law jurisdictions. There is no lack of economic analysis by American, European, and Taiwanese scholars, yet no consensus has been formed. This article advances a new framework based on allocative efficiency and institutional costs, arguing that 1) property law scholars need not consider theft deterrence in designing property doctrines such as good-faith purchase of chattels; and 2) using the price actually paid by purchasers is a better measurement of who values the resources more. Moreover, the market overt rule can be used to implement 2) above. Specifically, purchasers who have paid market value, bought the goods in question from an open market, and are not reasonably expected to know of unauthorized sale can acquire titles to the chattel on the spot. Original owners who fail to expend optimal prevention costs are not entitled to recover the goods in question, even when a good-faith purchaser did not buy the thing in an open market.

KEYWORDS: Allocative efficiency, production efficiency, theft rule, market overt rule, gross negligence, verification costs, prevention costs.

* Research Professor & Director of Center for Empirical Legal Studies, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.